
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

Material realizado en base a:

Enrique Barros. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Apuntes de clases de Pizarro y Peña.

INTRODUCCIÓN

El presente apunte está consagrado al derecho de la Responsabilidad Extracontractual. Comprende el estudio detallado de los distintos modelos de responsabilidad civil, de los requisitos para su configuración y de sus respectivas consecuencias, típicamente consistentes en el deber de reparar pecuniariamente el daño causado.

En particular, cuando se aborde el estudio de esta materia, resulta fundamental tener en mente los contenidos estudiados a propósito de la responsabilidad contractual. No solo porque estas materias suelen evaluarse de manera conjunta, sino también porque el estudio comparativo de ambos estatutos de responsabilidad permite una comprensión sistemática y coherente de la responsabilidad civil como un todo.

Por otro lado, en relación con el abordaje concreto al estudio de la responsabilidad extracontractual, es necesario tener en cuenta la relación entre la regulación del código civil y los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales al respecto. En este sentido, dada la escueta regulación legal por parte del código, y a causa de la creciente complejización de la vida en nuestras sociedades, una parte importante del desarrollo de las reglas y principios aplicables a la responsabilidad extracontractual ha correspondido a un desarrollo doctrinal y jurisprudencial.

Así, es muy importante que durante su estudio le pongan atención a las discusiones doctrinales que se han generado a lo largo de nuestra historia. También resulta recomendable mantener cierto grado de conexión con la actualidad jurídica, sobre todo en relación a eventuales fallos importantes que vayan saliendo.

Pese a lo anterior, es imprescindible ponerle mucho énfasis al estudio de las normas legales pues, en último término, ellas son la base y el sustento sobre el cual se erigen las instituciones de la responsabilidad extracontractual.

ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1 Generalidades	3
1.2 Modelos de atribución de responsabilidad y riesgos	4
1.3 Fines y valores en la responsabilidad patrimonial	8
2. Elementos de la responsabilidad por culpa o negligencia	14
2.1 Hecho imputable	14
2.2 Imputabilidad a título de culpa o dolo	18
2.2.1 Culpa	19
2.2.2 Presunciones de culpa	29
2.2.3 Dolo	41
2.3 Daño	42
2.3.1 Principios que rigen la determinación del daño indemnizable	43
2.3.2 Tipos de daño	45
2.3.2.1 Daños materiales o patrimoniales	46
2.3.2.2 Daños morales o extrapatrimoniales	49
2.4 Causalidad	56
2.4.1 Elemento naturalístico	57
2.4.2 Elemento normativo	58
2.4.3 Pluralidad de causas o causas concurrentes	62
2.4.4 Otros aspectos relevantes de causalidad	65
3. La acción de responsabilidad	67
3.1 Acciones preventivas	67
3.2 Acción indemnizatoria	67
4. Otros estatutos de responsabilidad	73
4.1 Responsabilidad del estado y de las municipalidades	73
4.2 Responsabilidad civil precontractual	74
4.3 Responsabilidad civil y responsabilidad penal	75
4.4 Responsabilidad contractual y extracontractual	76
5. Concurso o cúmulo de responsabilidad	79
Anexo I El problema de la carga de la prueba en el daño moral	82
Anexo II Los daños punitivos	83
Anexo III La antijuridicidad como requisito de la responsabilidad	84
Anexo IV La responsabilidad por el hecho de los animales	86

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES

1. Noción de responsabilidad civil

La responsabilidad civil es un juicio normativo que consiste en imputar a una persona la obligación de reparar pecuniariamente el daño que ha causado a otra.

La regla general en nuestro derecho es que las pérdidas y daños producidos por un accidente deben quedar donde caigan, esto es, que cada quien soporta el daño sufrido, salvo que exista una razón para atribuirle responsabilidad a un tercero.

En este sentido, la principal cuestión que debe resolver el estatuto jurídico de la responsabilidad civil consiste en determinar los criterios, fijar las condiciones o requisitos según los cuales las consecuencias patrimoniales del daño sufrido por una persona deben radicarse en el patrimonio de otra, por medio de la indemnización de perjuicios.

2. Estatutos de responsabilidad civil

En el código civil chileno, es posible encontrar dos estatutos de responsabilidad: el de **responsabilidad contractual** y el de **responsabilidad extracontractual** (o de responsabilidad delictual o cuasidelictual). Ambos estatutos comparten un objetivo común: dar lugar a una acción civil de indemnización de perjuicios, que persigue la reparación pecuniaria de los daños sufridos por el hecho de un tercero.

En el caso de la responsabilidad contractual, los perjuicios que se pretenden indemnizar derivan de la infracción de un contrato¹, mientras que en el caso de la responsabilidad extracontractual, éstos derivan de la infracción a un deber general de cuidado que las personas deben observar en sus encuentros espontáneos².

¹ Es por esto que se ha dicho que la responsabilidad contractual tiene un carácter secundario, pues la obligación originaria en materia contractual consiste en cumplir lo convenido, mientras que la obligación de indemnizar surge sólo una vez que el deudor ha incumplido la obligación contractual (de primer grado), como uno de los remedios judiciales que la ley confiere al acreedor para hacer frente al incumplimiento.

² En este sentido, el vínculo obligatorio en el ámbito extracontractual tiene un carácter originario, cuyo antecedente es precisamente haber ocasionado un daño infringiendo algún deber general de conducta.

Si bien en principio no hay impedimento legal para que el contrato sustituya a las reglas de responsabilidad extracontractual (regulando por vía convencional los riesgos cotidianos de la vida), ello sólo será posible en aquellos casos en los que el riesgo y las potenciales víctimas son perfectamente identificables *a priori* y siempre que se justifiquen los costos asociados a una negociación.

Por lo anterior, *las reglas de responsabilidad extracontractual siguen teniendo el carácter de estatuto general de la responsabilidad civil, y se aplican con carácter supletorio*, a todas aquellas situaciones en que no existe una relación obligatoria previa entre la víctima y el autor del daño, como ante el incumplimiento de obligaciones legales o cuasidelictuales.

1.2. MODELOS DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RIESGOS

Señalábamos que la regla general es que los daños deben ser soportados por quien los sufre, a menos que existan buenas razones para imponer al autor del daño la obligación de indemnizar los perjuicios. Existen principalmente tres modelos de atribución de responsabilidad que buscan determinar bajo qué supuestos ha de entenderse que se debe responder por los perjuicios causados:

1. Responsabilidad por culpa o negligencia

Este modelo señala que la razón para atribuir responsabilidad a un tercero radica en que el daño ha sido causado por su acción culpable, esto es, ha sido el resultado de una acción ejecutada con infracción a un deber de cuidado. Este deber puede ser establecido por el legislador, mediante la dictación de reglas de conducta orientadas a evitar accidentes (como ocurre en la Ley del Tránsito o en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente) o bien ser el resultado de una regla no legislada, definida por los jueces recurriendo a la costumbre o a diversos criterios prudenciales de diligencia y cuidado.

Bajo un régimen de responsabilidad por culpa, la negligencia no solo es el fundamento de la obligación de indemnizar, sino que también su límite, porque la obligación de reparar sólo nace a condición de que se haya incurrido en infracción a un deber de cuidado.

La responsabilidad por culpa o negligencia constituye el estatuto general y supletorio de responsabilidad extracontractual, y a él se refieren como regla general los artículos 2284, 2314 y 2329 del Código Civil.

Los elementos de este régimen general de responsabilidad civil son:

- i. la acción u omisión,

- ii. la culpa (negligencia) o dolo,
- iii. el daño, y
- iv. la relación de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño.

Desde un punto de vista económico, una regla de responsabilidad por culpa asigna los costos del accidente a quien lo causó mediando culpa o dolo y, en cualquier otro caso, los costos recaen sobre la víctima. Asimismo, resulta evidente que si ambas partes contribuyeron culpablemente a la producción del daño, entonces deben distribuirse los costos.

2. Responsabilidad estricta u objetiva

La responsabilidad estricta u objetiva tiene como antecedente el riesgo creado y no la negligencia, de modo que es indiferente el juicio de valor respecto de la conducta del autor del daño.

En este tipo de responsabilidad, la obligación de indemnizar es impuesta sin necesidad de calificar la acción del autor del daño, bastando que el perjuicio se produzca en el ejercicio de una actividad considerada riesgosa. En términos generales, se exige que el hecho se verifique dentro del ámbito de la actividad sujeta al régimen de responsabilidad estricta y que exista una relación de causalidad entre el hecho y el daño, prescindiendo del juicio de negligencia propio del régimen de responsabilidad por culpa³. Así, el rasgo distintivo de la responsabilidad estricta es que se prescinde de la negligencia como factor de imputación de la obligación indemnizatoria. Ahora, esto no quiere decir que en la responsabilidad estricta se prescinda del problema de la imputación. Para la mayoría de la doctrina, en este modelo de atribución de responsabilidad el factor de imputación es, precisamente, el riesgo creado.

La responsabilidad estricta es un régimen especial y como tal de derecho estricto, que opera sólo respecto de ciertos ámbitos de conducta o de tipos de riesgos previamente definidos por el legislador.

El establecimiento de estatutos de responsabilidad estricta ha sido justificado por razones de justicia correctiva (que atiende a la lesión de un derecho como razón suficiente para imponer responsabilidad), distributiva (ya que la víctima queda indemnizada con independencia de la conducta del responsable) y desde una

³ La responsabilidad estricta presenta una cierta analogía con las denominadas *obligaciones de garantía* del derecho contractual (como la obligación de saneamiento del vendedor en la compraventa), pues en virtud de este régimen se establece un verdadero deber general de garantía, que asegura a las potenciales víctimas que todo daño ocasionado en el ámbito de determinada actividad deberá ser reparado por quien la ejerce, sin exigir imputabilidad.

perspectiva económica, pues asigna los costos del accidente a quien lo causó, con prescindencia de que haya mediado culpa o dolo.

Es importante mencionar que, para algunos autores, la nomenclatura 'responsabilidad subjetiva/responsabilidad objetiva' resulta criticable como forma de distinguir el modelo de responsabilidad por culpa y el modelo de la responsabilidad estricta. Esto se debe a que, como veremos más adelante, la culpa se aprecia en abstracto, comparando la conducta efectiva del autor del daño con el modelo de una persona razonable. Así, la responsabilidad por culpa no consiste en un análisis subjetivo, sino objetivo.

Casos de responsabilidad estricta en el Derecho Chileno

Algunos ejemplos de responsabilidad estricta en nuestro derecho son los siguientes:

- a. Responsabilidad por *la tenencia* de animales fieros, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio (artículo 2327 del Código Civil), por los daños que dicho animal ocasione⁴. La víctima únicamente deberá probar que se trata de un animal fiero que no presta utilidad para la guarda o servicio de un predio y que el demandado lo tenía, para que éste sea obligado a indemnizar los daños que haya provocado, resultando inadmisibles las excusas de actuar diligente.
- b. Daño ocasionado por las cosas que se arrojan o caen desde la parte superior de un edificio⁵.
- c. Responsabilidad estricta del propietario del vehículo por los daños ocasionados por el conductor (artículo 174 de la Ley del Tránsito): Esta regla contiene una hipótesis de responsabilidad estricta por el hecho ajeno, en virtud de la cual el propietario del vehículo responde solidariamente con el conductor, y sólo puede eximirse probando que el vehículo le fue tomado sin su conocimiento o sin su autorización expresa o tácita, circunstancias que equivalen a casos de fuerza mayor (a condición de que quién lo conducía haya incurrido en negligencia).
- d. Daños ocasionados por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar: El dueño, armador u operador a cualquier título de la nave o artefacto naval que produzca el derrame o la descarga responden solidariamente por los daños que se causen.
- e. La del explotador de instalaciones nucleares: Esta materia está regulada en la Ley Nº 18.302, que en su artículo 49 señala expresamente que "la responsabilidad civil por daños nucleares será objetiva y estará limitada en la forma que establece esta

⁴ El artículo 2327 del Código Civil señala: "El daño causado por un animal fiero, de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que lo tenga, y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído".

⁵ El artículo 2328 I, en su primera parte, señala: "El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas". Es necesario mencionar que, para parte de la doctrina esto constituye una presunción de culpa, ver p. 40.

ley”.

- f. Responsabilidad del explotador de aeronaves por daños ocasionados en caso de accidente aéreo⁶. Está tratada en la Ley N°18.916, Código Aeronáutico, artículos 142 y siguientes.
- g. Daños ocasionados por aplicación de plaguicidas: Quien utiliza un plaguicida está sujeto a responsabilidad estricta por todos los daños que se sigan de su aplicación, aunque sean causados *en forma accidental*, es decir, sin culpa.

Rol de la causalidad en la responsabilidad estricta

El efecto de la responsabilidad estricta es la obligación de reparar todo daño que se produzca en el ámbito de la actividad respectiva.

Las reglas específicas que consagran responsabilidad estricta tienen por objeto crear un régimen de protección para ciertos riesgos, de modo que sólo las consecuencias que se sigan razonablemente de aquellos deben ser reparados. Por ello, la causalidad está especialmente determinada por el fin protector de la norma de responsabilidad estricta⁷. Así, en ausencia de la culpa, la causalidad tiene un rol determinante para establecer límites a la responsabilidad, ya que actúa como un elemento de control, evitando la extensión ilimitada de la responsabilidad civil.

Atendida la importancia decisiva de la causalidad en materia de responsabilidad estricta, la excusa del autor usualmente se limitará a negar la relación causal entre el daño y el ámbito de riesgo.

3. El seguro privado obligatorio

Garantiza la reparación de la víctima estableciendo el deber legal respecto de quien realiza la actividad susceptible de causar daño o de quien corre el riesgo de accidente, de contratar un seguro de responsabilidad.

Este sistema se rige por las normas de los contratos, pues la obligación de indemnizar a la víctima del accidente que pesa sobre la compañía de seguros emana del contrato de seguro. Si quien está obligado a asegurar desarrolla la actividad sin cumplir con ese

⁶ Respecto del empresario aeronáutico, la ley establece dos ámbitos de responsabilidad sin culpa: (a) El primero de carácter contractual, por los daños ocasionados a los pasajeros y la carga, con un límite de 4.000 U.F. por cada víctima, en caso de muerte o lesión, y de 1 U.F. por kilogramo de peso bruto de la carga. Se trata de una obligación de garantía, que opera por la sola ocurrencia del daño; y (b) El segundo de carácter extracontractual, respecto de los daños ocasionados a terceros en la superficie, a consecuencia de la acción de una aeronave en vuelo, o a la caída de todo o parte de una aeronave. Esta responsabilidad es de carácter estricto, pues sólo admite como excusas las causales de fuerza mayor definidas en la ley.

⁷ Ver causalidad, p. 48.

deber, se aplican las normas generales de responsabilidad contractual o extracontractual, según el accidente se produzca en el ámbito contractual (como en el caso del contrato de trabajo) o de relaciones espontáneas no sujetas a contrato (accidente causado por un vehículo motorizado, por ejemplo).

1.3. FINES Y VALORES EN LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

La vida en las sociedades modernas, cada vez más complejas e interrelacionadas, permite a las personas gozar de una prosperidad material que resultaría inaccesible por fuera de la vida en sociedad. Y, como contracara de este beneficio, la vida en sociedad también las somete al riesgo de sufrir perjuicios y daños en las interacciones espontáneas entre las personas. Como hemos dicho más arriba, las reglas de la responsabilidad civil tienen por objetivo delimitar las reglas y condiciones para fijar la obligación de indemnizar estos perjuicios por parte de quien los provoca.

En este contexto, los fines de la responsabilidad se refieren a las razones sustantivas para preferir el establecimiento de uno u otro régimen de responsabilidad civil y, por otro lado, a los principios que nos permitan guiar la interpretación de las reglas existentes dentro de cada estatuto de responsabilidad. En general, podemos adoptar dos enfoques para pensar los fines de la responsabilidad civil: el enfoque preventivo, vinculado a la eficiencia económica de las actividades sociales, y el enfoque de la justicia, vinculado a la armonía y el equilibrio en las relaciones sociales.

Desde el punto de vista de la prevención, el objetivo de la responsabilidad civil es prevenir los accidentes en un grado socialmente óptimo. Así, las reglas de la responsabilidad son pensadas como incentivos que deben guiar correctamente la actividad de los particulares en el contexto general de la vida en sociedad.

Desde el punto de vista de la justicia, el objetivo de la responsabilidad civil es reestablecer el equilibrio en las relaciones sociales cuando estas se ven turbadas por accidentes o por hechos dañosos. Así, las reglas de la responsabilidad son pensadas como mecanismos correctivos, que pueden ser analizados desde el punto de vista de quien cometió el daño (justicia retributiva); de quien sufrió el daño (justicia correctiva); y desde el punto de vista general de todos quienes podrían sufrir el daño (justicia distributiva). En los próximos párrafos se desarrollan estos dos fines.

A) La prevención

Desde el punto de vista de la prevención, el fin de la responsabilidad civil, es la óptima prevención de accidentes, esto es, el establecimiento de una regla tan rigurosa como sea necesario para evitar accidentes que causan un daño mayor al beneficio que reporta la actividad que los genera, pero sin llegar al extremo de inhibir la actividad de los

particulares. En este sentido, se supone que si el sistema legal pone el costo de los accidentes de cargo de quien los produce, entonces las personas van a tener incentivos para obrar con mayor cuidado para disminuir la probabilidad de accidentes.

La cuestión relevante será entonces determinar el nivel óptimo de prevención, es decir, aquél en que el beneficio social que reporta una actividad resulta mayor que el costo de evitar los accidentes que impone el sistema de responsabilidad. Para algunos, el sistema que mejor se adecúa a una lógica de prevención, es el de responsabilidad por culpa. Otros sostienen que se garantiza de mejor manera aquella función preventiva mediante el sistema de responsabilidad estricta.

Aquellos especialistas en el análisis económico del derecho que se declaran partidarios del sistema de responsabilidad por culpa como régimen general, destacan que la negligencia supone la inobservancia del cuidado debido, esto es, aquel cuidado que razonablemente podemos esperar de quien desarrolla una actividad. De ello se sigue que quien actúa observando el cuidado debido, cumpliría con el nivel de prevención que conduce al equilibrio óptimo entre el costo de evitar los accidentes (medidas de prevención) y los riesgos que la actividad supone.

Desde esta perspectiva, la aplicación de reglas de responsabilidad estricta sólo se justifica en casos en que el beneficio que reporta la actividad es notoriamente inferior al riesgo que ella misma genera (por ejemplo, al suponer el Código Civil que la tenencia de un animal fiero reporta a su dueño un beneficio definitivamente inferior al riesgo que provoca respecto de los demás y, por consiguiente, el óptimo de prevención exige el establecimiento de una regla de responsabilidad por el sólo hecho que el animal provoque daño a la persona o propiedad de otro).

Quienes son partidarios de un sistema generalizado de responsabilidad estricta, arguyen que este sistema obliga a aquellos que desarrollan una actividad riesgosa a internalizar el costo de los accidentes. En otros términos, en un régimen de responsabilidad estricta, el costo de indemnizar a las víctimas de accidentes provocados por la actividad será considerado como uno más de los componentes del precio del bien o servicio respectivo, distribuyéndose entre todos sus usuarios o consumidores.

Un segundo argumento en favor del sistema de responsabilidad estricta señala que la mejor regla para prevenir accidentes es la que aplica los incentivos en aquél que genera el riesgo, de manera que sea éste quien determine el grado óptimo de cuidado. Por regla general, quien desarrolla la actividad está en mejores condiciones para evitar el daño, y este sistema de responsabilidad estricta lleva a adoptar los resguardos más eficientes para evitar los accidentes, es decir, lleva a adoptar aquellos resguardos que tengan un costo comparativamente menor que las indemnizaciones que deberá pagar a las víctimas de los accidentes.

B) La justicia

Siguiendo a Aristóteles, podemos decir que la justicia es una virtud de las relaciones sociales, que consiste en el respeto al equilibrio y la armonía (“el justo medio”, como diría Aristóteles) entre los dos polos de la relación. La responsabilidad civil persigue el fin de la justicia en la medida en que busca reestablecer la armonía perturbada por el hecho dañoso, generalmente por medio de la obligación indemnizatoria. No obstante, es necesario tener en cuenta que el análisis de la responsabilidad desde la perspectiva de la justicia tampoco conduce a respuestas unívocas, pues dependerá de la perspectiva desde la que se observe el problema.

Así, según la forma en que analicemos la relación social, podemos distinguir tres ámbitos de la justicia. La justicia retributiva surge si analizamos la relación entre el autor y la víctima desde el punto de vista del autor del daño, con la finalidad de sancionarlo por el hecho dañoso. La justicia correctiva surge si analizamos la relación entre el autor y la víctima desde la perspectiva de la víctima del daño, con la finalidad de reparar el daño que ha sufrido. Por su parte, la justicia distributiva surge si analizamos la relación entre la persona que sufre un daño, y todas las demás personas que, estando expuestas al mismo riesgo de sufrir un daño, no lo sufren.⁸

1. Justicia retributiva como fin de la responsabilidad civil (óptica del autor del daño).

El derecho no nos exige particular heroísmo en nuestras relaciones recíprocas, sino comportarnos como debemos hacerlo, atendidas las circunstancias. Desde esta perspectiva, la pregunta clave que subyace a la responsabilidad civil indaga por la regla o norma de conducta que debemos observar en nuestro trato con los demás. La doctrina de la negligencia como condición de la responsabilidad civil, tiene su fundamento en un principio de justicia retributiva, porque esta responsabilidad se basa en la infracción del deber de respeto que tenemos hacia los demás. Así, el concepto clave de la justicia retributiva es la imputabilidad: el autor del daño es responsable *porque* ha causado un daño que le es imputable a título de culpa o dolo.

Algunas de estas reglas están formuladas por la ley (como ocurre con las normas básicas del tránsito vehicular o con las reglas administrativas de seguridad industrial). Otras responden a costumbres o usos normativos que la comunidad observa como

⁸ Es necesario acotar que, en un sentido histórico, la idea de justicia retributiva es la más antigua de estas concepciones de la justicia, y tiene orígenes tan antiguos como la ley del talión. (“ojo por ojo, diente por diente”). En cambio, las nociones de justicia correctiva y distributiva tienen su origen propiamente hablando en el pensamiento de Aristóteles y, en particular, en el libro V de la Ética a Nicómaco.

obligatorios. Pero también hay ocasiones en que no existe apoyo en una regla legal o social preexistente, y en tales casos es necesario construir hipotéticamente la regla que habría seguido una persona razonablemente juiciosa en tales circunstancias. Cualquiera sea el camino por el cual el juez llegue a la regla de conducta que debió ser observada, la responsabilidad es concebida como una sanción al autor del daño que se ha comportado de manera negligente o dolosa, consistente en reparar pecuniariamente a la víctima por este acto dañoso.⁹

2. Justicia correctiva como fin de la responsabilidad civil (óptica de la víctima del daño).

La justicia correctiva señala que si la víctima es afectada por una pérdida injusta debida a la acción de un tercero, éste debe responder, con prescindencia del factor de imputabilidad. La idea de justicia correctiva tiende, en consecuencia, a establecer una responsabilidad *prima facie* del autor del daño, pues atribuye el deber de repararlo a quien genera el riesgo. El problema será, entonces, determinar cuáles son las razones que el derecho admite para justificar al autor del daño.

En principio, la justicia correctiva apuntaría hacia el establecimiento de un sistema de responsabilidad estricta, en que basta la relación causal entre el hecho y el daño para que se genere responsabilidad.

Por otro lado, también el régimen de responsabilidad por culpa presumida adopta el criterio de la justicia correctiva, pues dichas presunciones de culpa establecen en principio la responsabilidad del autor del daño, a menos que éste pruebe que pese a haber actuado con el cuidado debido no ha podido evitar el accidente¹⁰.

Los principales argumentos que sustentan que se adopte una lógica de justicia correctiva en la responsabilidad civil señalan que, por una parte, se asume que psicológicamente la víctima de un accidente tiene una menor propensión al riesgo que quien desarrolla la actividad que genera ese riesgo. Intuitivamente se puede suponer

⁹ Es necesario acotar que la noción de la justicia retributiva tiene una menor vigencia práctica en comparación con la idea de justicia correctiva. En efecto, si bien el factor de la imputabilidad es un requisito de la responsabilidad extracontractual, este no es un criterio relevante para la determinación del monto de la indemnización de perjuicios, el cual se va a determinar por el daño efectivamente sufrido por la víctima. La manifestación más concreta de la noción de justicia retributiva en el derecho contemporáneo está dada por los así llamados daños punitivos. Al respecto, consultar el Anexo II.

¹⁰ La creciente expansión en el derecho nacional del régimen de presunciones de responsabilidad por vía jurisprudencial muestra que es posible, sobre la base de consideraciones latentes de justicia correctiva, acercarse al límite mismo de la responsabilidad estricta a partir de un sistema general de responsabilidad por negligencia.

que quien emprende una actividad está naturalmente más dispuesto a tolerar riesgos conexos a ella, que quien permanece en su rol pasivo de víctima potencial.

Desde otro punto de vista, se estima justo hacer que una persona responda por los resultados dañosos de las acciones que han sido emprendidas en su propio beneficio según el principio de que quien aprovecha las ventajas de una actividad debe soportar sus costos. En otras palabras, los efectos de una acción deben recaer en quien ha decidido emprenderla, y de ahí que la justicia correctiva tienda a establecer una especie de responsabilidad por el riesgo creado.

3. Justicia distributiva como fin de la responsabilidad civil (relación entre la sociedad toda y las víctimas de los ilícitos).

Según Aristóteles, la justicia distributiva tiene que ver con la proporción que existe entre el todo y cada una de sus partes. Ésta no tiene el carácter interpersonal que caracteriza a la justicia retributiva y correctiva, pues mientras éstas atienden a la relación justa entre la víctima y autor del daño, la justicia distributiva atiende a la desproporción entre la víctima afectada por el accidente y aquellos que están en una situación análoga de riesgo y no soportan daño alguno. El punto es que toda la sociedad se beneficia de las actividades riesgosas que terminan dañando a unos pocos. Por tanto, una consideración de justicia distributiva apunta a distribuir el costo del daño entre todos los beneficiarios del riesgo que lo genera.

Así, la justicia distributiva atiende a la aleatoriedad con que se distribuye la carga de llegar a ser víctima de un accidente, y pone acento en la forma más equitativa de hacer dicha distribución entre todos los candidatos a ser víctima de determinada actividad, o de la sociedad completa, según sea el caso. En tal sentido, esta especie de justicia invoca la solidaridad para con las víctimas de accidentes, corrigiendo la aleatoriedad con que estos se distribuyen.

En consecuencia, desde la perspectiva de la justicia distributiva, se pretende evitar la desproporción entre los costos asumidos por las víctimas de accidentes y el conjunto inmensamente mayor de víctimas potenciales, fundado en el beneficio que reportan las víctimas potenciales. Un ejemplo es la circulación de automóviles: toda la sociedad se beneficia de un medio de transporte rápido y eficiente, pero solo algunos terminan cargando el riesgo de los accidentes automovilísticos.

Los modelos más directamente dirigidos a la justicia distributiva, son el seguro social y el seguro privado obligatorio. Estos conducen derechamente a la *socialización del riesgo*, sea por vía pública, como ocurre cada vez que las víctimas son indemnizadas por el Estado con recursos recolectados por medio de impuestos, o por vía privada,

mediante el establecimiento de la obligación de contratar un seguro para desarrollar determinada actividad, como es el caso de la circulación de automóviles.

Los inconvenientes de un sistema de esta naturaleza son múltiples. Ante todo, se debilitan los lazos de recíproca responsabilidad que unen a una comunidad de personas, bajo el principio de que cada uno carga con las consecuencias de sus propios actos (característicos de la justicia retributiva y correctiva). Además, un sistema de seguros generalizados y compulsivos puede contribuir a que se debilite el sentido de lo correcto, pues la funcionalización del riesgo nos aleja del discernimiento de lo justo. Por último, el sistema de distribución del riesgo ha sido criticado desde el punto de vista de la eficiencia: por una parte, porque la dispersión del riesgo hace que los incentivos para evitarlo disminuyan; por otra parte, porque los costos asociados a un sistema generalizado de distribución (costos que supone la contratación y operación del seguro) hacen que en definitiva el *fondo a repartir* entre las víctimas sea menor que en otros sistemas.

Idea de justicia y sistemas de responsabilidad.

En definitiva, se puede comprobar que los argumentos de justicia operan en direcciones diferentes. Cada sistema jurídico evoluciona en uno u otro sentido, por vía legal o jurisprudencial, movido por las ideas normativas del óptimo de la prevención, la justicia retributiva, correctiva y distributiva que, en la práctica, resultan concurrentes entre sí. Lo cierto es que en casi todos los sistemas jurídicos actuales conviven sistemas de responsabilidad por culpa como regla general, con ámbitos de responsabilidad estricta, que frecuentemente están asociados a sistemas de seguro obligatorio.

CAPÍTULO 2. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD POR CULPA O NEGLIGENCIA EN EL DERECHO CHILENO

Los elementos¹¹ de este régimen general¹² de responsabilidad civil son: (a) la acción u omisión, (b) la culpa (negligencia) o dolo, (c) el daño, y (d) la relación de causalidad entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño¹³.

2.1. HECHO IMPUTABLE

La responsabilidad tiene por antecedente el hecho voluntario. No hay propiamente responsabilidad si no existe un daño reconducible a la conducta libre de un sujeto, que puede consistir en un hecho positivo (una acción), o en uno negativo (una omisión).

Dentro de este hecho voluntario, es posible distinguir dos elementos, uno de carácter externo, consistente en la conducta del sujeto, que corresponde a su dimensión material, y otro de carácter interno, que se refiere a la voluntariedad y expresa su dimensión subjetiva.

1. Dimensión material del hecho

En su dimensión material, el hecho voluntario se muestra en un comportamiento positivo, a través de una acción, o negativo, mediante una omisión. Por regla general, los daños relevantes para el derecho son los producidos a consecuencia de una acción, pues en el derecho civil no existe una obligación genérica de actuar para evitar daños a terceros.

El comportamiento negativo, la pura omisión, se verifica cuando frente a un riesgo autónomo, independiente de la conducta del agente, éste no actúa para evitar el daño o disminuir sus efectos, pudiendo hacerlo. En este sentido, no se debe confundir la omisión propiamente tal con la omisión en la acción, la que se produce en el ámbito más amplio de una acción positiva, cuando su ejecutor omite tomar las precauciones necesarias para evitar el daño.

¹¹ Esta sistematización de los requisitos necesarios para que se configure la responsabilidad extracontractual obedece a una construcción doctrinal que es, en todo caso, mayoritaria. No obstante, para algunos sectores específicos de la doctrina también se requiere el elemento de la antijuridicidad como requisito autónomo. Al respecto, consultar el anexo III.

¹² Este es el régimen común de responsabilidad en el derecho nacional, aplicable a todos aquellos casos que no están regidos por una regla especial diversa.

¹³ A pesar de coincidir en los tres últimos elementos, para ALESSANDRI, el primero de ellos corresponde a la *capacidad delictual o cuasidelictual*. Sin embargo, aunque existen buenas razones para considerar la capacidad como un elemento autónomo, se ha optado por tratarla como uno de los componentes del concepto de acción, en su aspecto subjetivo.

La omisión acarrea responsabilidad civil solo excepcionalmente, en aquellos casos en que una regla especial impone un deber en tal sentido. Esos casos son los siguientes:

- (a) Cuando la omisión es dolosa, es decir, cuando se pruebe que la omisión sólo tuvo por finalidad causar daño a otro.
- (b) Cuando se omite ejecutar un acto expresamente ordenado por la ley (culpa infraccional por omisión)¹⁴.
- (c) Cuando existe un deber especial de cuidado, atendidas las circunstancias, en virtud de la relación de cercanía existente entre quien sufre el daño y quien omite actuar para evitarlo (como el capitán de un barco con su tripulación o los padres con sus hijos).

2. Dimensión subjetiva del hecho

En su dimensión subjetiva, el hecho debe ser voluntario. La conducta sólo es voluntaria en la medida en que puede ser imputada a una persona como *su* hecho, lo cual supone necesariamente que el autor tenga discernimiento. Así, en esta dimensión subjetiva, la responsabilidad supone que la acción que causa el daño sea imputable a quien se le atribuye, esto es, que sea una acción voluntaria de quien es jurídicamente capaz.

a) Capacidad en materia extracontractual

La capacidad constituye una condición de imputabilidad de la responsabilidad civil. En efecto, la imputabilidad supone que el autor sea capaz, y ello exige algún grado mínimo de aptitud de deliberación para discernir lo que es correcto.

En materia civil, la regla general es la capacidad, según la norma del artículo 1446 del Código Civil. Por excepción, la ley declara incapaces a ciertas personas. En materia de responsabilidad extracontractual, el artículo 2319, inciso primero da la norma sobre el tema, señalando que "*no son capaces de delito o cuasidelito los menores de 7 años ni los dementes*", con lo que fija un umbral bastante más bajo que el existente en la responsabilidad penal y contractual¹⁵.

¹⁴ Ver artículo 494 números 12, 13 y 14 del Código Penal.

¹⁵ En materia penal, están absolutamente exentos de responsabilidad los menores de 14 años (artículo 10 N°2 del Código Penal), mientras que la capacidad civil en materia contractual se adquiere plenamente a los 18 años. Para ALESSANDRI esta diferencia de requisitos y la mayor amplitud de la capacidad civil delictual que la contractual "se debe a que el hombre adquiere la noción del bien y del mal mucho antes que la madurez y la experiencia necesarias para actuar en la vida de los negocios".

La falta de capacidad excluye la responsabilidad y, en consecuencia, frente al hecho de un menor, la víctima del accidente queda en principio privada de reparación. Pero puede ocurrir que el acto del incapaz se deba a negligencia de quien lo tiene a su cargo. En este caso, habrá *responsabilidad directa, personal y exclusiva de quien o quienes tienen el deber de cuidar al incapaz*, porque el daño no es atribuible a éste, sino precisamente a quien lo tiene bajo su cuidado (artículo 2319, inciso primero del Código Civil).

Esta responsabilidad que grava al custodio del incapaz es distinta de la responsabilidad por el hecho ajeno, cuya regla general se encuentra en el artículo 2320 del Código Civil, y que está sujeta a un importante régimen de presunciones de culpabilidad. Son análogas en cuanto en ambos casos existe responsabilidad por los actos de otra persona. Sin embargo, en la responsabilidad por el hecho ajeno existen dos responsabilidades, la de quien actúa provocando el daño, que debe probarse, y la de aquel que tiene al autor del daño bajo su dependencia o cuidado, que se presume. Pero ambos son perfectamente capaces. En cambio, si quien comete el daño es un incapaz sólo existe la responsabilidad del custodio. No existe por tanto, responsabilidad por el hecho ajeno, sino responsabilidad personal y directa, pues al incapaz no puede imputarse responsabilidad alguna.

En el caso de querer imputar responsabilidad por el hecho propio de quien tenía el deber de cuidar al incapaz, en principio se deberá probar la culpa del guardián. Con todo, el artículo 2321 contiene una importante excepción, al establecer una presunción general de responsabilidad de los padres por los delitos o cuasidelitos de sus *hijos menores*, que conocidamente provengan de su “mala educación, o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir”. Esta presunción se aplica indistintamente respecto de los hijos menores capaces e incapaces de delito civil, pues, según su tenor, se superpone a las reglas de los artículos 2319 y 2320 del referido código.

Dicho esto, corresponde analizar quienes son incapaces de delito o cuasidelito civil.

i. Incapacidad del demente

En términos generales, demente es aquella persona privada de razón.

En materia de responsabilidad extracontractual determinar cuándo una persona se encuentra privada de razón es una cuestión de hecho, que debe ser probada al ser opuesta como excepción perentoria en un juicio de responsabilidad. Sin embargo, es también una cuestión normativa, porque el concepto jurídico de demencia no es idéntico al de la medicina.

A su vez, es conveniente notar que la noción jurídica de demencia no es necesariamente coincidente en materia de responsabilidad contractual y extracontractual, ya que el umbral de deliberación exigido por el derecho puede diferir en una y en otra.

Ante todo, el decreto de interdicción no produce en materia de responsabilidad extracontractual efectos permanentes e irrefutables como ocurre en materia contractual. En esta, tiene el efecto de excluir la capacidad negocial, sin que sea posible alegar lucidez circunstancial (artículos 456 y 465 del Código Civil). Por el contrario, en materia extracontractual tal decreto es sólo un antecedente, que podrá servir de base para una declaración judicial específica de demencia en el juicio de responsabilidad, pero que no produce efectos necesarios.

ii. Incapacidad del menor

Como se anticipaba, en materia de responsabilidad extracontractual son incapaces los menores de 7 años. Es importante agregar que el Código Civil dispone que el juez deberá determinar si el menor de 16 años y mayor de 7 años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento y en este caso, se entenderá también incapaz. El discernimiento consiste en la capacidad de discernir la corrección y el riesgo que supone una determinada acción.

Resulta interesante analizar brevemente el objeto del juicio de discernimiento en materia civil. Existen dos alternativas para juzgar el discernimiento. La primera consiste en plantear el juicio como el juzgamiento de la aptitud del menor para discernir acerca de los efectos riesgosos o peligrosos de la acción, de modo que carece de discernimiento el menor que no está en situación de apreciar que una cierta acción es susceptible de dañar a una persona o a su propiedad. La segunda alternativa es referir el discernimiento a la capacidad del menor para discernir el patrón de debido cuidado, esto es, la posibilidad de distinguir aquello que es correcto de lo que no lo es. La opinión general en esta materia ha sido el análisis sobre si el menor era capaz de discernir el riesgo que suponía su acción.

Un último punto relevante en relación a la capacidad, dice relación con las personas jurídicas. En este sentido, las personas jurídicas están sujetas a las reglas generales, salvo lo que establezcan determinadas leyes especiales. Así, las personas jurídicas son capaces de responsabilidad extracontractual, tanto por el hecho propio, como por el hecho ajeno cometido por sus dependientes. Por lo tanto, es necesario distinguir entre los delitos y cuasidelitos imputables directamente a la persona jurídica, y aquellos que resultan imputables a sus dependientes.

El criterio aceptado en doctrina y jurisprudencia para dicha distinción es el siguiente: si el delito o cuasidelito ha sido cometido por el órgano administrador de la persona

jurídica, entonces ésta será directamente imputable. Si el delito o cuasidelito ha sido cometido por cualquier otro funcionario o empleado de la persona jurídica, entonces éste será directamente responsable, y la persona jurídica responderá por el hecho ajeno si es que concurren los demás requisitos, según las reglas generales.

b. Libertad en la acción

Para que la acción dañosa sea imputable a un sujeto se requiere, además de la capacidad, que exista voluntariedad, esto es, que la acción u omisión sean libres.

En esta voluntariedad elemental, que se expresa en el *mero control de la acción*, se agota el elemento subjetivo de la responsabilidad civil. No es siquiera necesario que el sujeto conozca los efectos de su conducta, basta que la controle.

Así, los actos que no están bajo el control de la voluntad son inimputables, del mismo modo que los actos de los incapaces. En consecuencia, no imponen responsabilidad los actos que son resultados de reflejos, los que tienen su causa en enfermedades como la epilepsia, o los cometidos bajo la sujeción de una fuerza externa suficiente para privar de voluntad.

En relación a la pérdida de discernimiento debida a una acción originariamente imputable al autor, como beber o drogarse, el Código Civil dispone expresamente, en su artículo 2318, que "*el ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito*". Esta responsabilidad se funda en que la ebriedad le es imputable, porque proviene de un acto voluntario. Si se mostrare que la ebriedad no es voluntaria, la privación de discernimiento o voluntad puede ser alegada como excepción de inimputabilidad.

2.2. IMPUTABILIDAD A TÍTULO DE CULPA O DOLO

El segundo elemento de la responsabilidad por negligencia es la culpa o dolo de quien causa el daño. Sin embargo, estos conceptos presentan radicales diferencias entre sí pues, como se ha visto, mientras la determinación de la culpa importa comparar la conducta dañosa con un modelo o patrón abstracto, el dolo nos lleva a indagar la subjetividad del autor del daño.

En los párrafos siguientes se analizarán separadamente la culpa y el dolo como fundamentos de la responsabilidad.

2.2.1 CULPA

La doctrina tradicional tendió a enfocar la responsabilidad preferentemente desde el punto de vista del sujeto que causaba el daño, considerando que la función de la indemnización era análoga a la de la pena (sancionar una conducta ilícita), y de ahí que en ambas se exigieran requisitos similares. Según este principio, el juicio de culpabilidad importaba establecer si el autor del hecho merecía o no la sanción por lo que el error de prohibición, las debilidades o carencias personales y la impericia del autor podían ser considerados como causales eximentes.

En la doctrina contemporánea, en cambio, la pregunta en torno a la responsabilidad se plantea de un modo diferente. Lo pertinente no es cómo actuó el sujeto específico atendidas sus circunstancias personales, sino como debió actuar en esas circunstancias una persona cualquiera. La culpabilidad aparece entonces como un juicio normativo respecto de la acción u omisión consideradas en abstracto, de modo que son irrelevantes los aspectos psicológicos o sociológicos del sujeto específico¹⁶.

Nuestro Código Civil no contiene entre las normas sobre delito y cuasidelito civil una definición especial de la culpa, siendo aplicable a este respecto la definición legal del artículo 44 del mismo cuerpo legal. En dicha norma el legislador optó claramente por seguir la noción romana de culpa, construida en relación a patrones abstractos de conducta (el *hombre de poca prudencia*, el *buen padre de familia* y el *hombre juicioso*), alejándose así del concepto moral, asociado a un reproche personal¹⁷.

1. Apreciación y determinación de la culpa

La culpa es un concepto normativo de conducta, que tiene una base real dada por las expectativas que las personas tienen acerca del comportamiento ajeno, expectativas que varían en el tiempo (de una época a otra) y en el espacio (de un lugar a otro). Una de las ventajas del patrón abstracto del hombre razonable es precisamente su flexibilidad para adaptarse a situaciones concretas muy diversas.

¹⁶ Por esto, resulta equívoca la idea de *responsabilidad subjetiva*, utilizada con frecuencia para referirse a la responsabilidad por culpa, toda vez que esta es de carácter objetiva porque no supone un juicio de reproche personal al sujeto, sino la comparación de su conducta con un patrón general y abstracto.

¹⁷ La definición de culpa del artículo 44 del Código Civil encuentra su natural campo de aplicación en materia contractual, lo que ha llevado a algunos a sostener que no sería aplicable tratándose de responsabilidad extracontractual. Sin embargo, nada impide que atendida su generalidad pueda ser extendida a este ámbito de la responsabilidad civil.

De lo anterior resulta que en materia extracontractual **la culpa se aprecia en abstracto**, esto es, obedece a una evaluación objetiva¹⁸, mediante la comparación de la conducta efectiva con un patrón de conducta debida. Esto quiere decir que el juez, al apreciar la culpa, no debe considerar las condiciones personales del autor, sino que ha de centrar su atención en su conducta, comparándola con la que habría observado el hombre razonable o prudente. Por esta razón se dice que las debilidades e ineptitudes de cada cual deben ser soportadas, por lo general, por sus portadores¹⁹.

Sin perjuicio de la apreciación abstracta de la culpa, ésta **se determina en concreto**, en cuanto se consideran las circunstancias de la acción u omisión. En efecto, la determinación del grado de cuidado que habría empleado el hombre razonable o prudente depende, por una parte, de la situación externa, y por otra, del rol social o calidad del autor (la calidad de experto, por citar un ejemplo). La determinación en concreto no implica que la culpa devenga en subjetiva, porque el rol social o la calidad del autor se consideran abstractamente, habida consideración de las circunstancias. Así, para apreciar si hay o no culpa de parte de un médico al practicar una operación urgente, se comparará su conducta con la de un médico prudente que se hallare en las mismas circunstancias. En este sentido la pregunta relevante será ¿cómo habría actuado un hombre prudente en esas circunstancias?

2. Estándar de culpa

El grado de culpa por el cual se responde es materia extracontractual es el de **culpa leve**²⁰, pues las referencias del legislador a la culpa o negligencia en este ámbito son siempre genéricas, y en consecuencia, se aplica lo dispuesto en el artículo 44, inciso segundo del Código Civil, según el cual “*culpa o descuido*, sin otra calificación, significa

¹⁸ Existen diversas razones para explicar esta tendencia a la objetivación. Ante todo, la disfuncionalidad de un juicio subjetivo, es decir, su incompatibilidad con la función que la responsabilidad civil tiene en la economía moderna y, en este sentido, la objetivación de la culpa es una concesión de lo particular a lo general. Por otro lado, en cuanto instrumento de justicia la responsabilidad civil mira a ambos sujetos, al autor del daño y a la víctima. En materia de justicia, la perspectiva de la víctima está dada por las expectativas razonables que ésta puede tener acerca del comportamiento de los demás, y en la construcción de esas expectativas no tiene cabida la discriminación sobre la base de aspectos subjetivos de cada cual, como son las deficiencias personales.

¹⁹ Excepcionalmente, puede ser relevante para fijar el nivel de cuidado que el autor del daño actúe como un experto. Lógicamente, si alguien desarrolla una actividad que plantea requerimientos profesionales particularmente exigentes o un cierto conocimiento o experiencia práctica calificados, la confianza comprometida respecto de su conducta es correlativamente mayor.

²⁰ Esta opinión es compartida por Ramón MEZA BARROS, *Manual de Derecho Civil. De las fuentes de las obligaciones*, Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1988, 8ª edición, pág. 252. Así también lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago, 9 de enero de 1941, confirmada por la Corte Suprema [cas. fondo] sin referirse a la materia (RDJ, Tomo XXXIX, sec. 1ª, pág. 79).

culpa o descuido *leve*". Asimismo, el artículo 2323 del CC se refiere al cuidado debido por el "buen padre de familia".

Sin embargo, parte de la doctrina nacional ha sostenido que en materia extracontractual se responde **de toda culpa**, incluida la levísima, pues la clasificación de la culpa en lata, leve y levísima que hace nuestro Código tiene una aplicación estrictamente contractual²¹.

En relación a esta posición, es importante tener en cuenta que si bien es cierto que la clasificación de la culpa se efectúa en el Código Civil a propósito de la responsabilidad contractual, ello ocurre sólo porque al tiempo de su redacción la responsabilidad extracontractual había experimentado una escasa evolución.

Por otra parte, la extensión de la responsabilidad hasta las hipótesis de culpa levísima exige que en cada una de nuestras actividades debamos emplear aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. De esta manera, en nuestro comportamiento cotidiano nos veríamos obligados a actuar según los estándares de cuidado recíproco más exigentes, llevando en la práctica a la responsabilidad por culpa hacia los límites de la responsabilidad estricta.

Pareciera, por el contrario, que la noción de culpa invoca naturalmente la idea de cuidado ordinario, pues atiende a lo que razonablemente podemos esperar de los demás en nuestras relaciones recíprocas. Culpable es quien actúa defraudando las expectativas que los demás tenemos respecto de su comportamiento, y dichas expectativas no son otras que aquellas que corresponden al actuar del hombre simplemente prudente, y no del especialmente cauteloso.

De ahí que aún quienes sostienen que en materia extracontractual se responde de toda culpa, no puedan eludir referirse al definirla a la *"falta de aquel cuidado o diligencia que el hombre prudente emplea en sus actividades"*, con clara alusión al estándar del buen padre de familia.

Lo anterior no debe inducir al error de creer que el nivel de cuidado exigible sea siempre el mismo, puesto que el hombre prudente determina su nivel de cuidado considerando las circunstancias que rodean su actuar. Por eso, la determinación del deber de cuidado es una tarea que atiende necesariamente a las circunstancias en que se desarrolla la actividad y al riesgo que ésta genera. Así, no es igual el nivel de cuidado exigible al médico que atiende espontáneamente a un accidentado en la vía pública, que al médico que efectúa una operación de peritonitis de urgencia en una posta pública de urgencia,

²¹ Esta opinión es sostenida por don Arturo Alessandri y Carlos Ducci, entre otros.

o que al especialista que realiza una operación programada con dos meses de anticipación.

3. La previsibilidad como requisito de la culpa²²

La culpa supone la previsibilidad de las consecuencias dañosas del hecho, porque el modelo del hombre prudente nos remite a una persona que delibera bien y actúa razonablemente. Como lo imprevisible no puede ser objeto de deliberación, dentro del ámbito de la prudencia sólo cabe considerar lo previsible.

Este requisito no hace referencia a un fenómeno psicológico, sino que aquello que *debió* ser previsto, atendidas las circunstancias. Por lo mismo, se valora en abstracto.

Además, la previsibilidad se refiere fundamentalmente a las consecuencias inmediatas de la acción. Una pregunta diferente es la relativa a los efectos dañinos subsecuentes al accidente. Este análisis se plantea más bien en relación a la causalidad.

Así ha sido sostenido por nuestra jurisprudencia que ha admitido que la previsibilidad es un requisito esencial de la culpa, y más aún, ha definido a ésta última como “una posibilidad de prever lo que no se ha previsto”²³.

La idea de que la previsibilidad sea connatural a la responsabilidad por culpa no es pacífica en doctrina y jurisprudencia. Se ha expresado que la norma del artículo 1558 del Código Civil sólo tendría aplicación en materia contractual, de lo cual cabría suponer que tratándose de responsabilidad extracontractual se responde de todo daño, incluso de los imprevisibles, aún cuando sólo se haya actuado con culpa.

Se argumenta que sólo en las obligaciones contractuales las partes estarían en condiciones de prever los daños que puede irrogar el incumplimiento, mientras que en materia extracontractual el daño es por naturaleza imprevisible. Además, se ha señalado que el ámbito de la responsabilidad contractual está determinado por la convención, que fija la esfera de riesgo por los cuales las partes responden.

4. La culpa como ilicitud o infracción de un deber de cuidado

²² La pertenencia de la previsibilidad al ámbito de la culpa no es una cuestión pacífica, pues como se expondrá, también adquiere relevancia en materia de causalidad. Mientras en sede de culpabilidad la pregunta sobre la previsibilidad se refiere a si es posible considerar ilícita una conducta que produce efectos dañinos imprevisibles, en sede de causalidad la previsibilidad es un elemento de juicio para definir cuáles consecuencias pueden ser consideradas como un efecto de la acción culpable.

²³ Corte Suprema, 29 de marzo de 1962 (RDJ, Tomo LXIX, sec. 4ª, pág. 21).

Según se ha señalado, la culpa se define a partir de un patrón abstracto o modelo genérico de persona que permite precisar en cada caso la conducta debida y compararla con la conducta efectiva.

Una acción es culpable (y a la vez ilícita) si infringe un deber de cuidado, que se establecerá determinando cuál habría sido, en esa situación, la conducta del modelo abstracto de persona. En otras palabras, la culpa establece el umbral entre el actuar ilícito y el lícito.

La cuestión que resta por resolver, es quién y cómo se efectúa la determinación en concreto de esos deberes de cuidado.

1. La culpa como infracción de un deber de cuidado establecido por la ley: Culpa Infraccional

En este tipo de culpa, los deberes de cuidado son establecidos por el legislador u otra autoridad con potestad normativa, por medio de una ley, reglamento, ordenanza, etc²⁴.

El principio básico es que cuando el accidente se produce a consecuencia de la infracción de alguna de estas reglas, el acto es considerado *per se* ilícito, sin que sea necesario entrar a otra calificación.

Por regla general, la determinación legal o reglamentaria de ciertos deberes no supone una regulación exhaustiva de la materia, de modo tal que aún en casos de una regulación legal, el juez está facultado para determinar deberes de cuidado no previstos por el legislador²⁵. Excepcionalmente, una regulación puede entenderse exhaustiva si su fin es dar mayor seguridad jurídica a un área de actividad, estableciendo una regulación orgánica de las conductas debidas. En tal caso, no podrían determinarse judicialmente deberes de cuidado adicionales a los establecidos por el legislador.

Es posible encontrar ejemplos de deberes de cuidado determinados por el legislador en el artículo 172 de la Ley del Tránsito (Ley N°18.290), en el Decreto Ley 211, para quienes infrinjan las reglas de la libre competencia, la Ley de Mercado de Valores, en las normas sobre seguridad en oleoductos, en las normas sobre control de medicamento y drogas, y en la legislación medioambiental.

²⁵ Así por ejemplo, puede ocurrir que atendidas las circunstancias particulares que rodean la acción, conducir al máximo de velocidad permitido sea imprudente, como ocurrirá cuando el vehículo se encuentra en condiciones deficientes o el camino está resbaladizo.

2. La culpa como infracción a un deber de cuidado derivado de usos normativos

A falta de ley, los deberes de cuidado pueden estar definidos por las costumbres o por los usos normativos.

Por regla general, las prácticas o usos existentes en determinada actividad no son en caso alguno vinculante a la hora de determinar el deber de cuidado, pues dichas prácticas o usos no son necesariamente justas.

Cuestión distinta ocurre con los usos normativos, esto es, aquellas reglas reconocidas espontáneamente como expresión de un buen comportamiento, es decir, de aquello que usualmente se tiene por debido. En principio, estos usos normativos pueden ser concebidos como una invocación a principios de prudencia, esto es, a la forma en que normalmente se conduce el hombre diligente. Se trata por regla general, de normas que emanan de sistemas de autorregulación profesional, manifestados en códigos de ética o de conducta, como los que rigen la actividad publicitaria o la de algunos colegios profesionales (como el colegio de abogados o el de arquitectos).

Tratándose de este tipo de reglas, la contravención es calificada *prima facie* culpable, en cuanto importa infracción a un deber de cuidado generalmente aceptado. En otros términos, si alguien actúa violando las normas de conducta de su propia actividad, en principio actúa culpablemente. Sin perjuicio de ello, según buena parte de la doctrina, nada obsta a que en determinados casos la regla pueda ser calificada de injusta y reemplazada por otra creada por el juez, y el principio subyacente es que este tipo de reglas respecto de la conducta establecida por el propio gremio o profesión no pueden ser opuestas en perjuicio de los demás.

3. La culpa como infracción a un deber general de cuidado definido por el juez

La regla general en el sistema de responsabilidad por culpa, es que el deber de cuidado sea construido por el juez sobre la base del hombre razonable y, en cuanto tal, se aplica a todos los casos en que dicho deber no ha sido predefinido por la ley o por otra fuente normativa. Así, frente a una situación concreta, el juez deberá determinar cuál era el comportamiento exigible a un hombre razonable o prudente, para luego compararlo con el comportamiento efectivo del sujeto y juzgar si éste ha actuado o no culpablemente.

Lo que en verdad sucede es que el juez construye *ex post* un deber de cuidado que, atendidas las circunstancias, el demandando debió descubrir como máxima de su acción. La determinación de los deberes de conducta según el modelo del hombre

prudente es el resultado de una tarea argumentativa. Lo relevante es entonces definir los criterios con los que se construyen argumentativamente esos deberes.

A continuación, se señalarán algunos ejemplos de las orientaciones que ha seguido la jurisprudencia nacional y comparada para determinar la conducta debida en casos concretos. Por regla general, estos criterios no actúan en forma aislada, porque lo normal es que en cada caso intervengan dos o más en distinta medida, y a veces en sentidos diversos.

- i. **Intensidad del daño:** Este criterio atiende a la magnitud del daño que supone una acción. Así, el descuido que se asocia a daños severos a la integridad física, por ejemplo, es juzgado en forma más estricta que aquel que sólo genera daños materiales. La amenaza de un daño muy intenso llevará normalmente a exigir que se adopten mayores precauciones para evitarlo.
- ii. **Probabilidad de la ocurrencia del daño:** La probabilidad es una variable acotada de la previsibilidad, pues mientras ésta muestra un resultado como posible, aquella mide el grado de esa posibilidad. Además, la probabilidad del daño es uno de los factores que permite determinar el riesgo²⁶. Lo usual es que los factores de probabilidad e intensidad del daño actúen conjuntamente para determinar la culpa. Así, una probabilidad menor pero asociada a un daño muy intenso será suficiente para imponer el deber de evitarlo. Lo mismo ocurrirá cuando se trate de daños de menor intensidad, pero con una alta probabilidad de ocurrencia.
- iii. **Valor social de la acción que provoca el daño:** El cuidado exigible para ejecutar una acción socialmente neutra será usualmente mayor al que se demanda tratándose de una acción de valor social elevado.
- iv. **Costo de evitar el accidente:** Si el daño pudo evitarse a costo razonable, el deber de cuidado exige que el daño sea evitado²⁷.
- v. **Tipo de relación entre el autor del daño y la víctima:** Si entre ambos existe una relación que impone deberes de lealtad recíprocos, como la negociación de un contrato, el deber de cuidado es mayor al que podría establecerse respecto a extraños.

²⁶ En términos estadísticos, el riesgo de una actividad puede definirse como función, por un lado, de la intensidad del daño que ésta amenaza ocasionar, y, por otro, de la probabilidad de que ese daño ocurra. Así, una actividad será riesgosa si el daño con que amenaza es grave (la pérdida de vidas, por ejemplo) y la probabilidad de que se concrete es elevada.

²⁷ Vinculando este criterio con los de intensidad y probabilidad del daño, el juez norteamericano Learned Hand elaboró una fórmula para determinar la culpa, según la cual una persona actúa en forma negligente si el costo de evitar un accidente es menor que el daño producido multiplicado por la probabilidad.

5. Causales de justificación

Las causales de justificación actúan sobre el ilícito, eliminando la culpabilidad. Su función, por tanto, es servir de excusa razonable para el hombre prudente y suponen un sopesamiento de bienes jurídicos. No existe un catálogo legal de causales de justificación, por ello, para ALESSANDRI, su existencia se desprende de los principios generales de nuestro derecho. Por otro lado, según el mismo autor, entre las causales de justificación que denomina “eximentes de responsabilidad”, se incluyen además el caso fortuito o fuerza mayor, la violencia física o moral, la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero.

Podemos mencionar como causales de justificación las siguientes:

i. La ejecución de actos autorizados por el derecho

Dentro de estos actos es posible distinguir: (a) los ejecutados en ejercicio de un derecho, (b) los ejecutados en cumplimiento de un deber legal, y (c) los autorizados por usos normativos.

- a) *El ejercicio de un derecho*: El ejercicio de un derecho elimina la ilicitud de la acción que causa el daño y, por ello, en principio no hay ilicitud en el hecho de que un restaurante se instale a media cuadra de otro ya existente y le prive de parte de su clientela, siempre que respete las normas de la libre competencia. El límite está dado por el abuso de derecho, esto es, por aquella actuación que se encuentra formalmente amparada por un derecho, pero que materialmente es antijurídico.
- b) *El cumplimiento de un deber legal*: Ciertamente, quien actúa en cumplimiento de un deber impuesto por la ley no comete ilícito alguno. Tal es el caso del agente de policía que priva de libertad al detenido, o del receptor judicial que traba un embargo.
- c) *Actos autorizados por usos normativos*: Queda excluida la culpa cuando la conducta da cuenta de usos o prácticas que son tenidos comúnmente por correctos. En este sentido, la incisión que hace el médico al operar conforme a las prescripciones de su *lex artis*, o las lesiones que ocasiona el futbolista que ejecuta una acción violenta, pero tolerada por las reglas del juego, no constituyen hechos ilícitos.
- d) *Obediencia debida*: Se refiere a la causal por haber observado órdenes emanadas de autoridad competente. Se ha señalado que éstas no actúan *persé* como eximentes de responsabilidad, pues sólo lo harán en la medida que en la misma no exista una ilegalidad manifiesta.

ii. El consentimiento de la víctima y aceptación de riesgos

Nada obsta a que en materia extracontractual puedan existir *acuerdos previos* entre el potencial autor del daño y la eventual víctima, ya sea en la forma de autorizaciones para realizar un determinado acto (caso en el cual el *acuerdo* es, en rigor, un acto jurídico unilateral), o de convenciones sobre responsabilidad, por medio de los cuales se acepta un cierto nivel de riesgo, se modifican condiciones de responsabilidad, etc.

En esta materia son particularmente importantes los deberes de información acerca la entidad del riesgo, pues no es posible entender que quien asume en forma voluntaria un riesgo quien conocidamente no está en situación de medirlo.

Cuando la víctima potencial presta su consentimiento autorizando la ejecución de un acto que puede causarle daño, realiza un acto de disposición que, como tal, está sujeto a límites según las reglas generales: (i) la autorización no puede importar condonación de dolo futuro, por prohibirlo el artículo 1465 del Código Civil; y, (ii) no puede significar la renuncia de derechos indisponibles (como la vida o la integridad física), en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del mismo Código.

Estos límites no operan respecto a la mera aceptación de un riesgo, como ocurre con el piloto de pruebas y con quienes se someten a experimentos con fármacos en desarrollo.

Para que la aceptación voluntaria del riesgo opere como causal de justificación, es necesario que el autor del daño haya proporcionado a la víctima información suficiente acerca de éste y de sus componentes (intensidad y probabilidad del daño).

iii. El estado de necesidad

En principio, quien ocasiona un daño para evitar uno mayor, actúa sin culpa.

El estado de necesidad es una excusa que se basa en la desproporción de los bienes en juego: la víctima soporta un daño que es substancialmente menor a aquel que el autor pretende evitar.

El estado de necesidad opera como causal excluyente de la responsabilidad en cuanto es propio del hombre prudente optar por un mal menor para evitar un mal mayor. Sin embargo, para que cumpla aquel rol deben cumplirse los siguientes requisitos: (a) que el peligro que se trata de evitar no tenga su origen en una acción culpable y, (b) que no existan medios inocuos o menos dañinos para evitar el daño.

iv. La legítima defensa

Actúa en legítima defensa quien ocasiona un daño obrando en defensa de su persona o derechos, a condición que concurran las siguientes circunstancias: (a) que la agresión sea ilegítima; (b) que no haya mediado provocación suficiente por parte del agente, (c) que la defensa sea proporcionada al ataque; y, (d) que el daño se haya producido a causa de la defensa.

6. Prueba de la culpa

El principio general es que la culpa debe ser probada por quien la alega, por aplicación de la regla del artículo 1698 del Código Civil, toda vez que el hecho culpable es uno de los supuestos de existencia de la obligación de indemnizar.

Para acreditar la culpa es necesario probar: (a) el hecho voluntario, que puede consistir en una acción u omisión; y, (b) el deber de cuidado que se supone infringido.

El objeto de la prueba variará según se trate de fundar la responsabilidad en una hipótesis de culpa infraccional, de infracción de usos normativos, o de un deber de cuidado construido por el juez.

1. *Culpa infraccional*: Si el deber de conducta se encuentra definido por una norma legal o reglamentaria, al demandante le bastará probar su infracción, constituyendo ese solo hecho una evidencia de culpabilidad.

Esto no significa que la culpa así establecida de sin más lugar a la responsabilidad, porque bien puede ocurrir que la infracción esté neutralizada por una causal de justificación, o por la falta de nexo causal entre la infracción y el daño, aunque técnicamente ésta última es una hipótesis de exclusión de la causalidad y no de la culpa.

2. *Infracción de usos normativos*: Tratándose de culpa que resulta de la infracción de usos normativos, además del hecho infractor, habrá que probar la existencia de estos usos.

A pesar de que el poder vinculante de las asociaciones profesionales o gremiales es cada vez más débil, los códigos de estas asociaciones siguen siendo estándares de conducta reconocidos, en la medida que no resulten contrarios a otros principios o reglas del derecho vigente y, en general, ellos tienden a facilitar la carga probatoria ya que actúan como un indicio acerca de la conducta debida, especialmente, en cuanto establecen deberes positivos de conducta de los asociados para con los terceros y con el público en general.

3. *Infracción de un deber de cuidado construido por el juez*: Tratándose de la

infracción de un deber de cuidado establecido por el juez, la prueba de la culpa exige un grado de actividad mayor del demandante. Como se ha visto, la determinación de la culpa en tal caso es el resultado de un juicio prudencial y, en consecuencia, el demandante debe probar todas las circunstancias que permitan al juez calificar el acto como negligente (esto es, contrario al deber de cuidado). Para efectuar ese juicio normativo acerca de la conducta debida, el juez considerará cuestiones de hecho que son determinantes en el cuidado que emplea un hombre razonable (como la peligrosidad de la acción, la probabilidad del daño, el valor social de la acción, el costo de evitar el accidente, la proximidad de la relación entre el autor del daño y la víctima, y los demás que resulten relevantes).

Para probar la culpa pueden emplearse todos los *medios probatorios* previstos por las reglas generales. A diferencia de lo que ocurre en materia de actos jurídicos, no rige aquí la limitación de la prueba testimonial, contemplada en los artículos 1708 y siguientes del Código Civil.

El juicio para determinar si se ha actuado o no con infracción de un deber de cuidado es eminentemente *normativo*, pues supone comparar la conducta efectiva con una regla de conducta, que expresa el estándar de conducta que debía observar el autor del daño. Por lo tanto, la decisión judicial es susceptible de control por la Corte Suprema a través del recurso de casación en el fondo²⁸.

2.2.2 PRESUNCIONES DE CULPA

El principio general en virtud del cual la culpa debe ser probada por quien la alega, sitúa con frecuencia a la víctima en una importante desventaja estratégica frente al autor del daño.

Por lo general, el demandante carecerá de los instrumentos probatorios para demostrar que el autor del daño no empleó la diligencia debida y, en los casos más complejos, difícilmente estará en condiciones de probar cual era el deber de cuidado que correspondía observar. En consideración a estas dificultades, el sistema de responsabilidad contempla presunciones de culpabilidad, cuyo efecto es invertir el peso de la prueba en favor de la víctima, a quien le corresponderá probar únicamente el hecho, el daño y la relación causal.

El Código Civil establece presunciones de culpabilidad referidas al hecho propio (artículo 2329), las que se refieren al hecho de las cosas (artículos 2323, 2324, 2326, 2327 y

²⁸ La tendencia inicial de la jurisprudencia nacional fue a considerar el juicio de culpabilidad como una cuestión de hecho. En la actualidad no existe un criterio uniforme en la materia.

2328) y las que se refieren al hecho ajeno (artículos 2320 y 2322). A continuación, analizaremos cada una de ellas.

1. Presunción de culpabilidad por el hecho propio (artículo 2329 del Código Civil)

Consagración

Esta presunción encuentra su consagración legal en el artículo 2329 del Código Civil, el que dispone:

"Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

Son especialmente obligados a esta reparación:

1.º El que dispara imprudentemente un arma de fuego;

2.º El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche;

3.º El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él".

Evolución

Ha existido una importante evolución en la forma en como el artículo 2329 del Código Civil ha sido comprendido por la doctrina.

Inicialmente, la doctrina y cierta jurisprudencia consideraron que el artículo 2329 del Código Civil no era sino una repetición de la norma del artículo 2314, cuya única peculiaridad consistía en citar algunos ejemplos o casos de aplicación del principio general de responsabilidad por culpa.

La primera explicación del artículo 2329 bajo una hipótesis de presunción de culpa fue formulada por Carlos Ducci (en su tesis de grado) en 1936, probablemente inspirado en la jurisprudencia de la Corte de Casación de Colombia, que había concluido que la norma establecía una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de actividades caracterizadas por su peligrosidad.

Luego, Alessandri siguiendo a la doctrina francesa y cierta doctrina colombiana, extendió el ámbito de la presunción señalando que el artículo 2329 establece "una presunción de culpabilidad cuando el daño proviene de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente". Según esta tesis, un hecho que por su naturaleza se presume culpable es,

por ejemplo, un choque de trenes, pues “los trenes deben movilizarse en condiciones de no chocar”.

En contraposición, Ramón Meza Barros ha sostenido que el inciso primero de la disposición contendría el principio general de la culpa probada, mientras que el inciso segundo sería una enumeración de casos específicos en que rige una presunción de culpabilidad.

Hay que señalar, por último, que la jurisprudencia coincide en señalar que la enumeración del artículo 2329 no tiene carácter exhaustivo, y ha considerado otros hechos como reveladores de negligencia, tales como los derrumbes que durante la demolición de un edificio causan daños a terceros o la muerte de un transeúnte causada por una línea eléctrica extendida en condiciones peligrosas.

Argumentos para sostener que en el artículo 2329 del Código Civil se establece una presunción de culpa por el hecho propio

Los más diversos argumentos han sido planteados para justificar que el artículo 2329 contempla la presunción de culpabilidad por el hecho propio de quien causa el daño:

- i. *Argumentos exegéticos:* son ilustrativos de la intención del legislador:
 - a) La ubicación del artículo 2329, inmediatamente después de las normas que establecen presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno (artículos 2320 y 2322) y por el hecho de las cosas (artículos 2323 a 2328).
 - b) El enunciado inicial de la norma, “*por regla general todo daño...*”. En verdad, todo parece indicar que el legislador quiso establecer una regla de clausura del sistema de presunciones que contempla el Código Civil. Según ALESSANDRI, de esta forma se quiso dictar una regla que comprendiere los demás casos análogos que pudiesen haberse omitido.
 - c) Esta es, por lo demás, la única forma de dar sentido y utilidad a la disposición, pues de lo contrario habría que aceptar que se trata de una innecesaria repetición de la regla del artículo 2314 del Código Civil.
- ii. *Razones de texto:* Este concepto, ilustrado por los ejemplos del inciso segundo, se refiere a una conducta que por si misma tiende naturalmente a ser negligente, aún antes de prueba alguna. Es una referencia a un actuar que *pueda ser* calificado como descuidado y no a algo que es. El artículo 2329 no exige que se haya acreditado que el daño proviene de dolo o culpa para imponer la obligación de repararlo, sino que obliga al autor a indemnizar cuando es razonable suponerlo, dando a entender que mientras no se establezca lo contrario, pesa sobre el autor del daño la obligación de indemnizar. Los ejemplos del art. 2329 también contribuyen en este sentido, pues todos se refieren a hechos que por si solos son expresivos de culpa.

- iii. *Experiencia y la razón:* Se atribuye en principio responsabilidad a otro, cuando el sentido común y la experiencia indican que el daño provocado en tales circunstancias usualmente se debe a culpa o dolo del que lo causa.
- iv. *Punto de vista de la justicia correctiva:* La presunción de culpa por el hecho propio se justifica porque resulta a menudo el único camino para poder construir en la práctica la responsabilidad del autor del daño. La presunción es de especial relevancia en caso de accidentes que se deben a algún error en un complejo proceso industrial o de servicios, sin que sea posible determinar, sin embargo, el acto u omisión concretos que lo provocaron²⁹.

Condiciones de aplicación de la presunción

La presunción de responsabilidad por el hecho propio del artículo 2329 del Código Civil reconoce al menos tres grupos de casos en que su aplicación resulta natural:

- 1) *Peligrosidad desproporcionada de la acción:* Quien actúa en ámbitos riesgosos, sea por la probabilidad o la intensidad del daño, esta obligado a adoptar todos los resguardos para evitar que ocurra un accidente.
- 2) *Control de los hechos:* Tratándose de daños ocasionados por quien está en condiciones de controlar todos los aspectos de su actividad, como ocurre con las personas está a cargo de procesos productivos complejos, quien está en mejor posición relativa para procurarse medios de prueba es precisamente el autor del daño. Mientras no se demuestre que fue debido a un hecho por el cual no responde el fabricante o el prestador del servicio, la culpa puede ser presumida.
- 3) *El rol de la experiencia:* Finalmente, existe una buena razón para aplicar la presunción cuando, conforme a la experiencia, cierto tipo de accidentes se deben más frecuentemente a negligencia que a caso fortuito. En otras palabras, si probada la relación causal entre el hecho y el daño, éste último resulta razonablemente atribuible a culpa del autor, debe aplicarse la presunción de responsabilidad por el hecho propio del artículo 2329 del Código Civil.

Efectos de la presunción

Las presunciones consisten en inferencias de hechos que se pretenden probar a partir de otros hechos conocidos.

²⁹ Por ejemplo, de los productos defectuosos (fármacos, alimentos), a falta de una legislación que establezca, como en otros ordenamientos, una regla de responsabilidad estricta.

Parece razonable señalar que esta presunción puede ser entendida como una prueba en principio, consistente en la apariencia de culpa, que alterará el peso de la prueba en la medida que el demandado no muestre una explicación más razonable acerca de cómo pudo ocurrir el accidente por una causa distinta a su propia negligencia. Es decir, se trata de una presunción simplemente legal.

2. Presunción de culpabilidad por el hecho ajeno (artículos 2320 y 2322).

Consagración

La presunción de responsabilidad por el hecho ajeno está consagrada en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, que disponen, respectivamente:

Art. 2320. "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

Así los progenitores son responsables del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso.

Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho".

Art. 2322: "Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista.

Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes".

El principio general está establecido en el artículo 2320 inc. primer del Código Civil, que señala: "Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado". Esta norma *se aplica genéricamente a todas las relaciones de dependencia o cuidado*, de modo que las situaciones específicas referidas en los demás incisos del artículo 2320 son puramente ejemplares.

En el Derecho chileno³⁰ la responsabilidad por el hecho ajeno está construida sobre la base de un **doble ilícito civil**: el del dependiente, que causa el daño directamente, y el de quien lo tiene bajo dirección o cuidado (*guardián*), cuya culpa es legalmente presumida³¹. La culpa del guardián consistirá en no haber actuado con el cuidado necesario para evitar que el tercero ocasione daños, ya sea al elegir, instruir o vigilar a éste último.

El fundamento de esta presunción es la existencia de *un vínculo de autoridad* entre el guardián y el autor del daño. Se ha entendido que esta relación es una cuestión de hecho. Por ello, puede no ser suficiente la existencia de un vínculo formal (como un contrato de mandato, por ejemplo), si el tercero actúa en forma independiente, sin estar sometido a un régimen de subordinación ni a obedecer instrucciones continuas. Por el contrario, son imaginables situaciones en que existe dependencia aunque no existe vínculo formal alguno (aprendiz que realiza una práctica en una empresa).

Casos de presunción de responsabilidad por el hecho ajeno

Por una parte, el artículo 2320 del Código Civil contiene una enumeración no taxativa de casos específicos de situaciones de dependencia o cuidado que dan lugar a la presunción de responsabilidad por el hecho ajeno:

- i. *Presunción de culpa de los padres por los hechos de los hijos menores*³²: A pesar de que el Código restringe la presunción a los casos en los cuales el niño vive con sus padres, debe entenderse que se refiere a aquellos que están sujetos al deber legal de cuidado personal. La presunción solo comprende los actos que están bajo el ámbito de cuidado de sus padres, pero no aquellos que el menor realiza bajo el cuidado de otras personas.

³⁰ A diferencia de lo que ocurre en nuestro derecho, parte del Derecho Comparado construye la responsabilidad por el hecho ajeno como una forma de responsabilidad estricta, que suele denominarse *vicaria*. En virtud de ella, establecida la relación de dependencia y el hecho ilícito que causa daño cometido por el dependiente se hace responsable al guardián.

³¹ Es posible apreciar una notable diferencia en la responsabilidad contractual. Como se señalaba, la regla general es que en materia extracontractual sólo existe responsabilidad por el hecho ajeno si el *guardián* ha incurrido a su vez en culpa. En el ámbito contractual, en cambio, la responsabilidad del guardián es estricta (ver arts. 1590 y 1679 del Código Civil).

³² En este punto cabe tener presente al Art. 2319. Los incapaces carecen de legitimación pasiva y como los infantes y los dementes son incapaces, responden por los daños causados por estos las personas a cuyo cargo se encuentren, siempre y cuando se establezca la culpa del guardador o la persona que tiene a su cargo al incapaz. Para que aplique esta hipótesis del artículo 2320, tanto el tercero civilmente responsable como el hijo que causa el daño tienen que ser capaces.

Con todo, los padres suelen ser responsables en términos amplios de la conducta de sus hijos menores, cuando ésta sea atribuida a la mala educación o hábitos viciosos que les han dejado adquirir³³ (art. 2321).

- ii. *Presunción de culpa de los guardadores por el hecho de los pupilos que viven bajo su dependencia y cuidado:* La norma se refiere a la guarda que tiene por objeto el cuidado personal del pupilo, excluyéndose los guardadores limitados a la administración de los bienes.
- iii. *Presunción de culpa de los jefes de colegios:* La presunción ha de entenderse limitada al tiempo en que los alumnos están bajo el cuidado del colegio.
- iv. Además la doctrina distingue los casos *de responsabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes*, en la que se comprenden propiamente la responsabilidad del empresario por los hechos de sus dependientes, así como la de los artesanos por el hecho de sus aprendices (ambas referidas en el artículo 2320 IV del Código Civil) y, la de los amos por la conducta de sus criados o sirvientes (artículo 2322 del mismo código).

Requisitos para que opere la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno

Para que pueda aplicarse la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno que establece el artículo 2320 del Código Civil, presumiéndose la culpa del *guardián* por el hecho del dependiente, es necesario que concurren los siguientes requisitos:

- 1) *Que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito civil:* A su respecto, la víctima debe acreditar la concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil, esto es, la existencia de un hecho voluntario y capacidad del dependiente, la culpa o dolo, el daño y la relación causal³⁴.
- 2) *Que exista una relación de autoridad entre éste y el tercero que responde por él:* La víctima debe acreditar además la existencia de una relación de autoridad o dependencia entre quien haya ejecutado el hecho ilícito y el tercero cuya responsabilidad se persigue³⁵. En opinión de la jurisprudencia, ésta es una

³³ Respecto de los hijos menores, cabe tener presente la regla del 2321 del CC. Se ha señalado que el CC establecería una regla de responsabilidad estricta u objetiva. En efecto, el Código señala que los padres serán siempre responsables en el evento que los daños causados provengan conocidamente de la mala educación o de los hábitos viciosos que los padres los hayan dejado adquirir.

³⁴ Nada impide que respecto del hecho del dependiente pueda operar además la presunción general de culpabilidad por el hecho propio, contenida en el artículo 2329 del Código Civil.

³⁵ En tal sentido, se ha fallado que "tratándose de la responsabilidad indirecta establecida para los patrones en los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, correspondía al querellante probar la

cuestión de hecho, que se da incluso con prescindencia de un vínculo formal.

Efectos

Establecida la responsabilidad por el hecho ajeno, la víctima puede dirigir su acción indemnizatoria en contra del autor del daño o del tercero³⁶, pues según el artículo 2317 del Código Civil, ambos son solidariamente responsables³⁷.

Por su parte, el tercero obligado a la reparación de los daños causados por el dependiente dispondrá de acción en contra del autor para obtener el reembolso de lo pagado, siempre que éste haya actuado sin orden de aquél, según establece el artículo 2325 del mismo Código.

Descarga de la presunción

La presunción de culpabilidad por el hecho ajeno es simplemente legal y, en consecuencia, puede ser desvirtuada mediante prueba en contrario. Con todo, la excusa del *guardián* se encuentra definida en el mismo artículo 2320 inciso final en términos exigentes, al señalar que: "*cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho*".

De este modo, para desvirtuar la presunción el tercero debe acreditar que aún actuando con la diligencia debida le ha sido *imposible impedir el hecho*, lo que en la práctica exige a menudo probar la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

situación de dependencia del causante de los hechos ocurridos" (Corte Suprema, 21 de septiembre de 1966, RDJ, Tomo LXIII, sec. 4ª, pág. 251). También se ha rechazado un recurso de casación en el fondo por infracción al artículo 2320 del Código Civil, fundándose para ello en que tal norma no puede estimarse transgredida si los jueces del fondo, valorando la prueba rendida, estiman que no se ha configurado la exención de responsabilidad contemplada en el inciso final de dicho artículo (Corte Suprema, 13 de mayo de 1971, RDJ, Tomo LXVIII, sec. 1ª, pág. 128).

³⁶ Se sostiene que en la responsabilidad por el hecho ajeno concurren dos ilícitos. Por una parte, el del agente directo del daño. De otro lado, el del tercero civilmente responsable, a quien se le imputa presuntivamente una culpa *in eligendo* o *in vigilando*.

³⁷ Pizarro y Peña destacan el debate jurisprudencial que se ha generado en relación a la determinación respecto a si la responsabilidad por el hecho ajeno descrita en los artículos 2320 y 2322 implica solidaridad en el pago de la indemnización (a favor de la víctima), o se trata simplemente de una obligación subsidiaria por parte del tercero civilmente responsable. La Corte Suprema ha señalado que no se verifica solidaridad pues, siguiendo a Alessandri, no cabe entender que, en los casos de responsabilidad por el hecho ajeno, el ilícito ha sido cometido conjuntamente por el agente del daño y por el tercero. El Tribunal Supremo da a entender que se trataría de un único ilícito cometido por el agente directo, por el cual no responde sólo éste, sino también el tercero. La regla del Art. 2317, que consagra la solidaridad en el ámbito extracontractual exige, según la Corte Suprema, que el ilícito haya sido cometido de manera simultánea o coetánea por los obligados al pago.

La jurisprudencia nacional ha ido desarrollando un proceso de objetivación de la responsabilidad del tercero civilmente responsable. Esta expansión de la responsabilidad por el hecho ajeno la ha llevado hasta la frontera de la responsabilidad *vicaria*, mediante la limitación las excusas de diligencia que puede interponer el tercero civilmente responsable³⁸.

Responsabilidad del empresario

En el derecho nacional, la presunción de culpabilidad del empresario por el hecho de sus dependientes tiene como fundamento al artículo 2320 inciso cuarto, que se refiere a ella en forma específica, y el artículo 2322 del mismo código, que fue tempranamente extendido por la jurisprudencia a esta materia³⁹.

Las principales diferencias entre ambas disposiciones consisten, ante todo, en que el artículo 2322 define de manera más estricta el ámbito de responsabilidad, al señalar que ésta sólo se refiere al tiempo en que el dependiente se encuentra en ejercicio de sus funciones, mientras que el artículo 2320 IV se refiere en general a la relación de dependencia o cuidado, entendida como una especie de cuidado o vigilancia personal.

Las excusas son asimismo diferentes en uno u otro caso: el artículo 2322 exige probar que los criados o sirvientes han ejercido sus funciones de un modo impropio “que los amos no tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente”, mientras en el artículo 2320 la excusa está formulada de manera general, con clara alusión a la relación entre el deber de cuidado y la posibilidad de impedir el hecho.

³⁸ Por ejemplo, tratándose de desvirtuar la presunción de culpabilidad de los padres y guardadores por el hecho de los menores que se encuentran bajo su cuidado, se ha estimado que es necesario acreditar la existencia de hechos que denoten un cuidado permanente de dichos menores, argumento que en la práctica conduce a que la responsabilidad sea inexorable, pues el accidente se produce precisamente porque en el momento de su ejecución los padres no ejercen vigilancia.

³⁹ Por el contrario, la tendencia generalizada del derecho comparado en esta materia es hacia la responsabilidad estricta de los empresarios por el hecho de sus dependientes. Diversas razones, desde la perspectiva de la justicia y de la eficiencia, permiten justificar esta posición. Por una parte, parece justo que quien goza de los beneficios de la actividad de sus dependientes, como ocurre con el empresario, asuma también los riesgos de errores o faltas en el proceso de producción o de prestación del servicio. Desde la perspectiva de las expectativas de la víctima a ser efectivamente reparada del daño injustamente sufrido, la responsabilidad estricta del empresario permite superar el grave inconveniente que representa la carencia de recursos del dependiente, que en la mayoría de los casos transforma a la responsabilidad civil en una cuestión puramente teórica. Además, la ampliación de la responsabilidad del empresario por actos de sus dependientes, tiene funciones preventivas, pues es él quien está en mejores condiciones de controlar los riesgos de su actividad.

Para que opere la presunción de culpabilidad del empresario es necesario:

- 1) *Que el dependiente haya incurrido en un delito o cuasidelito civil:* las exigencias probatorias de la responsabilidad por culpa enfrentan a la víctima a la difícil tarea de individualizar al dependiente que ocasionó el daño, al interior de sistemas productivos cada vez más complejos. Por esta razón, la doctrina y jurisprudencia han aceptado la noción de *culpa difusa*⁴⁰, en virtud de la cual no es necesario identificar al autor concreto del daño, mientras que la culpa se atribuye a la organización empresarial en su conjunto.
- 2) *Que exista una relación de cuidado o dependencia entre el autor del daño y el empresario:* La jurisprudencia nacional ha tendido a interpretar la noción de cuidado o dependencia de manera extensiva, señalando que se expresa en la capacidad de impartir órdenes o de vigilar la actividad de otro.
- 3) *Que el daño sea ocasionado en el ámbito de la dependencia o del ejercicio de las funciones del dependiente:* La jurisprudencia nacional ha entendido esta exigencia de conexión entre el hecho ilícito y la función en términos amplios y ha estimado suficiente que el hecho se cometa “con ocasión” del desempeño de esas funciones.

Responsabilidad de las personas jurídicas

Las personas jurídicas responden civilmente tanto por el hecho propio y por el hecho ajeno^{40 41}.

- 1) *Responsabilidad por el hecho propio:* La persona jurídica responde por el hecho propio cuando el ilícito ha sido cometido por un *órgano*⁴² en ejercicio de sus funciones.

⁴⁰ Sin embargo, cabe preguntarse si las hipótesis de culpa difusa son más bien un medio argumental para dar por establecida la responsabilidad de la empresa por el hecho propio de la entidad empresarial, usualmente organizada como persona jurídica.

⁴¹ Según Pizarro Wilson, sería necesario unificar la responsabilidad civil de la persona jurídica por el hecho del órgano y por el hecho ajeno. Cosa distinta es la posible responsabilidad personal de los dirigentes. Si estos actúan extralimitándose en sus funciones, serán personalmente responsables.

⁴² En principio, son órganos de una persona jurídica todas las personas naturales que actuando en forma individual o colectiva, están dotadas por la ley o los estatutos de poder de decisión, como ocurre, por ejemplo, con la junta de accionistas, el directorio y el gerente en una sociedad anónima.

Cabe tener presente el reconocimiento que ha realizado la jurisprudencia de la denominada *culpa anónima o difusa*, en virtud de la cual, la persona jurídica es responsable por los actos que naturalmente pertenecen al ámbito de cuidado de sus administradores, sin que sea necesario individualizar al causante inmediato del daño, como ocurre, por ejemplo, en los daños causados por productos defectuosos. La responsabilidad de la persona jurídica por el hecho propio está sujeta a las reglas generales de la prueba de ese tipo de culpa: por regla general deberá ser probada por la víctima que hace valer la pretensión indemnizatoria, a menos que se cumplan las condiciones para aplicar la presunción general de culpabilidad por el hecho propio del artículo 2329.

- 2) *Responsabilidad por el hecho ajeno*: La persona jurídica responde por el hecho de sus dependientes en los mismos términos que el empresario persona natural, es decir, también se aplica la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno y, en consecuencia, se aplica lo expuesto en relación con la responsabilidad del empresario.

3. Presunción de culpabilidad por el hecho de las cosas (artículos 2323, 2324, 2326, 2327 y 2328).

La responsabilidad por el hecho de las cosas obedece a la siguiente hipótesis general: Un sujeto padece un daño causado por una cosa animada o inanimada. Un tercero, cuya conducta no ha incidido directamente en el daño, debe, sin embargo, responder en razón de la propiedad que tenía sobre la cosa, o en razón del deber de vigilancia que debía ejercer sobre ella.

En materia de responsabilidad por el hecho de las cosas la ley sólo contempla presunciones específicas⁴³, referidas a los daños causados por el hecho de animales, por la ruina de edificios y, por la caída de objetos desde la parte superior de un edificio.

Presunción de culpa por el hecho de animales

El artículo 2326 del Código Civil presume la culpabilidad del dueño por los daños causados por un animal, aún después que se haya soltado o extraviado. El dueño podrá exculparse probando que el daño, la soltura o el extravío del animal no se deben a su culpa ni a la del dependiente encargado de guarda o cuidado. En este último caso, a la presunción de culpabilidad por el hecho del animal se agrega una presunción de culpabilidad por el hecho del dependiente.

⁴³ El Código Civil se aparta en esta materia del Código francés, cuyo artículo 1384 dispone, en general, que se responde por el hecho de las cosas que se tienen bajo custodia (*garde*).

La misma presunción se aplica a toda persona que se sirve de un animal ajeno, quien será responsable en los mismos términos que el dueño frente a terceros, pero tendrá acción de reembolso contra este último, si el daño causado se debió a un vicio del animal que el dueño debió conocer e informarle⁴⁴. La víctima del daño podrá dirigir su acción de responsabilidad tanto contra el dueño como contra aquel que se sirve del animal, pues frente a ella ambos responden solidariamente, sin perjuicio de la acción de reembolso que pueda corresponder.

Cabe distinguir esta hipótesis de la consagrada en el artículo 2327 del Código Civil el cual, como ya se ha señalado, consagra un caso de *responsabilidad estricta por el hecho de animales fieros que no reporten utilidad para la guarda o servicio del predio*.

Presunción de culpa por la caída de objetos desde la parte superior de un edificio

El artículo 2328, inciso primero, establece una presunción de culpabilidad en caso de daños causados por la cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, respecto de todas las personas que habitan la misma parte de aquel. Si los responsables son varios, la indemnización se dividirá entre todos ellos, lo que constituye una excepción al principio de la solidaridad establecido en el artículo 2317 del Código Civil.

La exculpación exige la prueba de que la caída del objeto se debe a culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso sólo ésta será responsable⁴⁵.

Presunción de culpa por los daños ocasionados por la ruina de un edificio.

Los artículos 2323 y 2324 del Código Civil presumen la negligencia del dueño del edificio por el daño que cause su ruina, provocada por la omisión de las necesarias reparaciones. Se trata de una regla de desplazamiento de *onus probandi*, puesto que el dueño podría eximirse de responsabilidad acreditando caso fortuito o fuerza mayor. Si el daño fue causado por defectos en la construcción de un edificio, la responsabilidad principal recae sobre el arquitecto, o sobre quien aportó los materiales del edificio (art. 2324 en relación al 2003 n° 3)⁴⁶.

⁴⁴ ALESSANDRI propone el ejemplo del propietario de un caballo que “no obstante saber que tiene el hábito de patear y de morder, no lo da a conocer al arrendatario o comodatario del mismo: si éste es obligado a reparar el daño que el caballo causó a un tercero, puede repetir por el monto de la indemnización en contra del dueño”.

⁴⁵ Además de la acción indemnizatoria, artículo 2328, inciso segundo, contempla una acción pública para que se remuevan de la parte superior de un edificio u otro paraje elevado objetos que amenacen caída y daño.

⁴⁶ Cabe tener presente que, en relación a esta materia, el Código Civil concede acciones preventivas: la acción posesoria especial de querrela de obra ruinosa, tratada en los arts. 932 al 935; y la acción general de prevención por daño contingente, de los artículos 2333 y 2334.

2.2.3. DOLO

El Código Civil en el art. 44, inciso final define al dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. De esta manera, el dolo está en el extremo opuesto de la culpa.

Esta definición se asimila a un concepto de *dolo directo*, en el que el propósito de la acción es precisamente dañar, y por ello, la conducta es considerada *per se* ilícita y genera siempre responsabilidad para su autor.

Al ser un concepto tan exigente, requiere acreditar la intencionalidad del autor del hecho, lo que producido que el dolo sea bastante inusual como fundamento de la responsabilidad civil. Por esa misma razón, las hipótesis de dolo eventual, en que el daño es aceptado como consecuencia de la acción para el caso de que éste se produzca, son usualmente asimilables bajo la culpa grave⁴⁷. Por esto podríamos considerar que la definición de dolo en materia civil pierde buena parte de su sentido práctico.

Diferencias entre el dolo y negligencia

Contrariamente a lo que ocurre en materia penal⁴⁸, tratándose de la responsabilidad civil extracontractual los efectos del dolo y la culpa grave son, en principio, idénticos a los de la mera negligencia, toda vez que el monto de la indemnización depende de la extensión del daño.

⁴⁷ Enrique Barros destaca algunas diferencias entre culpa grave y dolo, aunque sus efectos sean en principio los mismos: (a) Prueba del dolo (A efectos de dar por establecida la culpa grave, bastará acreditar la conducta efectiva y los hechos que muestran que se ha incurrido en esta especie de negligencia, sin que sea necesario probar intención alguna); (b) Abuso de derecho (En sentido estricto, se actúa en abuso de un derecho si se tiene la precisa intención de causar daño. Luego, la responsabilidad que se funda en el ejercicio abusivo de un derecho tiene como antecedente el dolo directo, no la culpa grave); (c) Cláusulas de exoneración de responsabilidad (Las cláusulas de este tipo no pueden excluir jamás el dolo directo, en cambio, en lo que respecta a la culpa grave, en principio no hay dificultades para que sea materia de una cláusula de exoneración de responsabilidad, siempre que ésta se refiera a ella en forma específica).

⁴⁸ En sede penal es posible encontrar responsabilidad penal por delitos de peligro como el manejo en estado de ebriedad en que sanción se asigna por un reproche a la conducta del autor. Por otro lado, para el Derecho Civil sólo son relevantes las conductas culpables si de ellas se sigue un perjuicio para el demandante, no siendo suficiente la mera negligencia. El daño es condición imprescindible, puesto que la principal función de la Responsabilidad delictual es la reparación íntegra del mismo. Aquí no se toma en cuenta el desvalor de la acción, sino nada más el desvalor del resultado. En este sentido, no existe responsabilidad civil por peligros.

En la práctica los jueces, al momento de valorar el daño moral, no son indiferentes a la gravedad del ilícito, ni a la intensidad del daño sufrido. Los jueces han tendido a asignarle al daño moral una función latente de pena civil, además de la estrictamente reparatoria. Ello trae por consecuencia que los daños provocados por el dolo o culpa grave tienden a dar lugar a indemnizaciones por daño moral mayores que las debidas a la mera negligencia. Es necesario insistir en que esto es una práctica jurisprudencial, y que ha sido criticada por la doctrina.

La doctrina tradicionalmente ha sostenido que la norma del artículo 1558 del Código Civil no es aplicable a la responsabilidad extracontractual, de modo que ésta comprendería, tanto si hay dolo o culpa grave, como si solo se ha incurrido en culpa, la reparación de los perjuicios previstos e imprevistos, en el entendido de que debe ser indemnizado todo daño.

Sin perjuicio de ello, Barros discrepa de esta opinión. A su juicio, la previsibilidad del daño está de tal modo vinculada a la responsabilidad por culpa, que reaparece como requisito bajo diversas formas. En este sentido, aunque en principio la responsabilidad extracontractual comprende la reparación de todo daño, según la expresión del artículo 2329 del Código Civil, ocurre que para dar por establecida esa responsabilidad es necesario construir normativamente los conceptos de culpa y de causalidad, de modo que si en esas sedes la previsibilidad es elemento condicionante de la responsabilidad por culpa, quedan fuera de su ámbito reparatorio natural los perjuicios imprevisibles (por mucho que se proclame la aplicación restrictiva del artículo 1558 del Código Civil). De esta manera, no se respondería de perjuicios imprevisibles ya que el hombre prudente no puede responder de aquello que no era capaz de prever.

2.3. DAÑO

Concepto de daño

El Código Civil no contiene un concepto de daño. En doctrina han coexistido dos conceptos diferentes. En un sentido estricto, el daño ha sido entendido como la lesión o pérdida de un *derecho subjetivo* de la víctima; en un sentido amplio, se ha afirmado que es toda “pérdida, disminución, detrimento o menoscabo” que se sufre en la persona o bienes. Doctrina y jurisprudencia se han inclinado mayoritariamente por el segundo concepto, en virtud del cual todo interés legítimo y relevante es un bien jurídico digno de ser cautelado.

En principio, se entiende que es legítimo un interés que no es contrario a derecho. En general, se determina a través de las convenciones sociales acerca de lo correcto e incorrecto, y también mediante los derechos de la personalidad, cautelados por la Constitución.

El daño debe ser además relevante o significativo. Los beneficios de la vida en sociedad exigen inevitablemente ciertos grados recíprocos de tolerancia respecto a turbaciones provocadas por los demás. Así, la noción de daño excluye aquellas incomodidades o molestias que las personas se causan recíprocamente como consecuencia normal de la vida común.

Rol del daño en la responsabilidad civil

El daño es un elemento esencial en la responsabilidad civil, tanto a nivel contractual como extra contractual.

El daño tiene una doble funcionalidad en la responsabilidad civil:

- **Condición:** sin daño no se puede configurar la responsabilidad civil, a diferencia, por ejemplo de la responsabilidad penal.
- **Objeto:** el propósito de la responsabilidad civil es la reparación de los perjuicios. En este sentido, el daño determinará la extensión de la responsabilidad y de la consecuente reparación.

Principio rector

El principio general en materia de indemnización es que ésta comprende **todo daño**, es decir, que la indemnización debe ser íntegra, debiendo producirse una equivalencia entre el daño generado y la indemnización pagada. De este mismo principio se deriva el impedimento de indemnizar a la víctima más allá del daño, no pudiendo quedar ésta en mejor situación de la que se encontraba antes del accidente⁴⁹.

Cabe hacer que este principio se aplica sin dificultades a los daños patrimoniales, más no a los morales, cuya indemnización tiene, como veremos, una función satisfactiva más que reparatoria.

2.3.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO INDEMNIZABLE

Principios que rigen la determinación del daño indemnizable

1) La indemnización debe ser completa

⁴⁹ En el derecho angloamericano, el principio es, por regla general, el mismo. Sin embargo, en dicho ordenamiento, existen los "daños punitivos", que consisten en una indemnización en dinero que percibe la víctima y que tiene por función no la reparación del daño, sino inhibir al causante del accidente para que cause daños en el futuro, fijando una suma mayor al monto correspondiente a la reparación del daño causado.

En opinión de BARROS, de este principio emanan las siguientes consecuencias: i) La indemnización comprende tanto el daño material como el daño moral; ii) La indemnización comprende reajuste e intereses, que se cuentan de distinta forma dependiendo la especie de daño (patrimonial o moral) y iii) A *contrario sensu*, la indemnización sólo comprende el daño efectivo y no puede convertirse en fuente de enriquecimiento para la víctima, con la reserva de la evolución jurisprudencial que atribuye a la indemnización del daño moral no sólo un fin compensatorio, sino, además, uno estrictamente sancionatorio (pena civil).

2) Sólo comprende daños directos

Tratándose de responsabilidad extracontractual, el requisito de que el daño sea directo expresa más bien una exigencia de causalidad, cuyo sentido es evitar que la indemnización se extienda indefinidamente en la cadena causal entre el hecho y sus consecuencias.

3) El daño debe ser cierto

La doctrina tradicionalmente ha distinguido entre el daño cierto y el puramente eventual o hipotético, que no concede acción indemnizatoria.

En verdad, la exigencia de certidumbre es característica del daño emergente. El lucro cesante, en cambio, se refiere por definición a una probabilidad basada en el curso normal de los acontecimientos, que supone una estimación razonable de la situación en que se habría encontrado la víctima de no mediar el hecho ilícito.

La certidumbre del daño no se opone a que el daño puede ser futuro. Se exige que éste sea la prolongación natural de un estado actual de las cosas.

4) El daño debe probarse

El daño material puede ser acreditado haciendo uso de todos los medios de prueba. En lo que respecta al lucro cesante, estos medios consistirán usualmente en presunciones e informes periciales.

En relación al daño moral, buena parte de la doctrina ha señalado que no requiere prueba, siendo suficiente que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño. Otros han señalado que se acredita mediante presunciones⁵⁰.

⁵⁰ Revisar Anexo I, en el cual se desarrolla en extenso el problema de la carga de la prueba en relación con el daño moral.

Cabe tener presente que atendida la naturaleza de los bienes o intereses lesionados, su determinación no está sujeta a parámetros exactos, y está entregada a la apreciación prudencial del juez.

5) Sólo comprende los daños sufridos personalmente por la víctima⁵¹

La circunstancia de que se exija un daño personal plantea la cuestión de la procedencia de la indemnización de *daños mediatos o daños por rebote*. Específicamente, la pregunta a responder es si la muerte o incapacidad física de una persona a consecuencias de un accidente, otorga acción a aquellos que se encuentran en una situación de cercanía con la víctima, y que en consecuencia, también se ven afectados. La verdad, es que todo aquel que a consecuencia del accidente se ve privado de los ingresos que le proporcionaba la víctima o sufre un gran dolor por la pérdida de un ser querido, sufre un daño patrimonial de carácter personal y por consiguiente, tiene una acción directa en contra del autor del daño.

6) La regulación del monto de la indemnización es facultad privativa de los jueces del fondo.

La doctrina y jurisprudencia tradicionalmente han entendido que la facultad de fijar el monto de la indemnización es privativa de los jueces del fondo, pues se trataría de una mera cuestión de hecho que escapa del control de la Corte Suprema por medio del recurso de casación.

2.3.2. TIPOS DE DAÑO

El artículo 2314 del Código Civil, que contiene el principio general de la responsabilidad por culpa, se refiere sólo genéricamente a la *indemnización*, sin atender a los tipos de daño⁵².

Atendiendo a la naturaleza del bien lesionado, los daños reparables han sido clasificados tradicionalmente en dos grandes categorías: Daños materiales o patrimoniales y daños morales o extrapatrimoniales. Todos estos daños pueden ser a su vez presentes o futuros.

⁵¹ De particular interés resulta la acción indemnizatoria cuando la víctima es *persona jurídica*. Estando fuera de duda que la persona jurídica tiene acción para exigir la reparación de los daños patrimoniales, se plantea la pregunta respecto del daño puramente moral. Descartada la hipótesis de los daños al prestigio que tienen un componente patrimonial (inequívocamente indemnizable), es dudoso que a las personas jurídicas resulte aplicable un concepto de daño que se refiera al dolor, a los afectos y a los sentimientos.

⁵² No ocurre lo mismo en materia contractual, en la que el artículo 1556 establece que la indemnización de perjuicios comprende el *daño emergente* y el *lucro cesante*.

2.3.2.1. DAÑOS MATERIALES O PATRIMONIALES

Se manifiesta en la diferencia entre el estado y posición económica de la víctima después de ocurrido el accidente, y la situación en que hipotéticamente se encontraría en caso de que éste no hubiere ocurrido. Los daños patrimoniales tienen la ventaja de ser avaluables en dinero, dado que tienen un valor de mercado.

a. Daño emergente

Consistente en la pérdida o disminución patrimonial, actual y efectiva que sufre la víctima a causa del accidente. Puede consistir en la destrucción o el deterioro de cosas que poseen valor económico, en los costos en que ha de incurrir la víctima a causa del accidente, o bien, en un perjuicio puramente económico⁵³.

b. Lucro cesante

Puede definirse como la pérdida del incremento neto que habría tenido el patrimonio de la víctima de no haber ocurrido el hecho por el cual un tercero es responsable.

La determinación del lucro cesante considera un grado razonable de probabilidad en la percepción de los ingresos futuros, y obedece a una proyección del curso normal de los acontecimientos, atendidas las circunstancias particulares de la víctima ⁵⁴ . La certidumbre del daño debe ser calificada en el caso del lucro cesante, pues rara vez habrá certeza de que el provecho se habría efectivamente producido. El cálculo del lucro cesante exige, en consecuencia, aplicar un *cálculo probabilístico* de su efectiva ocurrencia.

El lucro cesante se determina usualmente por medio de presunciones e informes periciales. La prueba deberá demostrar usualmente que la víctima percibía ingresos, y que los habría seguido percibiendo de no mediar el daño. En otros casos deberá

⁵³ Los daños económicos o puramente patrimoniales, en tanto, son aquellos que no se traducen en detrimento de cosas determinadas, pero que, sin embargo, afectan al patrimonio. Tal es el daño que sufre el comerciante que es víctima de competencia desleal, si su negocio pierde valor a consecuencia de publicidad engañosa. A diferencia de lo que ocurre en el *common law*, en nuestra tradición jurídica nada obsta para incluir estos daños en la reparación, pues bajo el principio de la diferencia toda pérdida patrimonial neta da lugar a un daño indemnizable.

⁵⁴ Existen casos en que esa probabilidad es cercana a la certeza, como ocurre en general con el dinero. En ese evento, el lucro cesante será igual al interés que la víctima habría ganado de no mediar el hecho.

mostrarse una expectativa razonablemente probable de que se habría obtenido el beneficio.

c. La pérdida de una chance o de una oportunidad

La pérdida de una chance o de una oportunidad consiste en una categoría moderna de daños en la que se incluyen todos aquellos casos en los que el agente dañante, con su actuación u omisión, ha interrumpido un proceso con el que la víctima tenía probabilidades de conseguir una ganancia o evitar una pérdida, por encontrarse en la situación idónea para ello. En esta hipótesis, se desconoce si la negligencia causó efectivamente el daño, pero sí se sabe que al menos destruyó una oportunidad de evitarlo.

Este tipo de daño se caracteriza porque para la víctima existe un bien aleatorio que se encontraba en juego, y el agente dañoso destruyó ese potencial de oportunidades con su acción u omisión negligente. Se señala que el bien es aleatorio, en tanto, aun sin la negligencia, la víctima podría no haber obtenido el beneficio o evitado el perjuicio.

La Corte de Casación francesa (de dónde proviene esta noción) ha definido a este tipo de daño como "la desaparición actual y cierta de una eventualidad favorable".

Ejemplos de casos de pérdida de oportunidad o chance:

- Abogado que omite presentar un recurso y hace perder al cliente la chance de ganar el juicio;
- Notario que olvida certificar un documento, haciendo perder al cliente una oportunidad de negocio;
- Transportista que lesiona al caballo antes de la carrera, haciendo perder a su propietario la posibilidad de acceder al premio;
- Accidente que impide a un estudiante rendir un examen y titularse;
- Acto de competencia desleal (como una publicidad comparativa engañosa) que impide a un competidor aumentar su clientela;
- Médico que omite un examen, privando al paciente de la oportunidad de someterse a un tratamiento, o cuando sin ajustarse a la *lex artis* no se sana una herida, perdiendo el paciente las chances de evitar una invalidez;
- Retraso del vuelo de un avión, que hace perder al cliente la posibilidad de cerrar un negocio; etcétera.

En todas estas hipótesis existe para la víctima un bien aleatorio que se encontraba en juego (ganar el proceso, cerrar el negocio, recobrar la salud, evitar la muerte, obtener un premio, acceder a una profesión, etcétera) y el agente destruyó ese potencial de oportunidades con su acción u omisión negligente.

Ya que solo existe certeza y causalidad respecto de la pérdida de la oportunidad, pero no de la ganancia (o evitación de pérdida) en sí, la indemnización se reduce a una estimación del valor de esa chance desaparecida. De esta forma, el cálculo se realiza a partir de dos elementos: la probabilidad de la oportunidad y el beneficio (o evitación del daño) probables. Es por este motivo que no se indemniza la totalidad de la eventualidad favorable sino una fracción de ésta.

Resulta relevante distinguir este tipo de daño con el lucro cesante. Podemos encontrar las siguientes diferencias:

- a) Reconocimiento normativo: el lucro cesante se encuentra reconocido en el artículo 1556 de nuestro Código Civil, a diferencia de la pérdida de la oportunidad, que por ser una institución moderna, no tiene reconocimiento legal expreso, sino que es una elaboración doctrinal y jurisprudencial.
- b) Perjuicio: el daño sufrido es distinto en cada uno. En el lucro cesante se pierden utilidades futuras, mientras que en la pérdida de la oportunidad, se pierde la posibilidad de obtener un beneficio o de evitar un daño
- c) Certeza de la pérdida: en el lucro cesante, el perjuicio es indiscutiblemente cierto, aún cuando su evaluación pueda ser discutible. En la pérdida de la chance, la pérdida misma es incierta.
- d) Alcance de la reparación: el monto de la indemnización en el lucro cesante es completo, mientras que en la pérdida de la chance es parcial, correspondiendo a un porcentaje de la ganancia esperada (probabilidad de la oportunidad * utilidades probables).
- e) Monto de la indemnización: lo anterior determina que el monto de la indemnización sea mayor en el lucro cesante.

En Chile, la jurisprudencia ha sido muy reacia a admitir la pérdida de oportunidad o de chance como categoría de daño patrimonial. En general, podemos señalar que no ha existido un tratamiento orgánico o sistemático de la aceptación de su reparación, y ha tendido a asimilarse, erradamente, a un lucro cesante imperfecto (con baja oportunidad de ocurrencia) o a un daño eventual, meramente probable (y consecuente, no es reparado).

Podemos citar un caso en que la Corte Suprema acogió, la doctrina de la pérdida de una chance, en la causa rol 2074-2009, cuya sentencia fue dictada en enero del año 2011. En el juicio en cuestión, se demostró que el médico realizó una biopsia de manera negligente, con lo cual no detectó un melanoma maligno. Así, la víctima estuvo por más de un año sin acceder al tratamiento necesario, lo cual redundó en que su calidad de vida disminuyera notablemente y que, en última instancia, terminara falleciendo.

La Corte determinó que no podía establecerse una relación causal entre el error de diagnóstico y la muerte de la víctima, pues aparentemente los tumores ya se habían difundido, y el tipo de cáncer del que se trataba carecía de tratamientos efectivos. No obstante, sí reconoció que dicho error la privó de acceder a tratamientos paliativos, con lo que hubiera evitado parte de los males que sufrió: “en relación a la circunstancia de haberse privado a la paciente tanto de la posibilidad de haber tenido una mejor calidad de vida si hubiera recibido la medicación adecuada para estos casos, durante el tiempo que no supo de su enfermedad, como también de la posibilidad de haber accedido a un tiempo de vida superior al que tuvo ...” (considerando 12º); y además “habiéndosele privado también de haber podido aspirar a una sobrevida, aun cuando inexorablemente por la enfermedad que padeció iba a morir, todo lo cual permite concluir que en la especie existió para ella una pérdida de chance” (Considerando 13º)

Pese al caso citado, es necesario recalcar que la figura sigue siendo de muy baja aceptación jurisprudencial

2.3.2.2. DAÑOS MORALES

El daño moral ha sido objeto de reparación sólo en el último siglo. El Código Civil no contiene una definición de daño moral, y la única norma que indirectamente se refiere a él en el título respectivo, lo hace para excluir su reparación, a propósito de la injuria (artículo 2331).

Los daños morales son inconmensurables en dinero, es por ello que la indemnización de los mismos tiene una función compensatoria.

a. Evolución del daño moral en el derecho nacional

En nuestro derecho, el daño moral fue objeto de un desarrollo eminentemente jurisprudencial. La primera sentencia que reconoce la indemnización por daño moral fue dictada en 1922, por la Corte Suprema. En ese caso, se indemnizó el daño moral de afección (causado por la pérdida de un hijo). Luego de 1922, se comenzó a indemnizar el daño moral experimentado a consecuencia de daños físicos. El daño moral se encontraba vinculado a una lesión física. En la década de 1950 se comienza a indemnizar el daño moral puro, que no se encuentra vinculado a un perjuicio físico, a una lesión física o a la muerte, sino que a la afectación ilegítima o antijurídica de un derecho personalísimo, como el honor, la honra o el prestigio⁵⁵.

⁵⁵ Esta evolución ha tenido un efecto fundamental en el ámbito de la responsabilidad civil, a saber: en todas las hipótesis en que se presenta un daño físico o la muerte de la víctima principal, el daño moral ha pasado a absorber a los demás rubros de daños. El foro, la práctica profesional, y así también la jurisprudencia, han privilegiado la indemnización del daño moral, en desmedro de los daños materiales. De ahí que el lucro cesante no tenga más que una pobre

En relación a su admisibilidad en los diversos estatutos de la responsabilidad civil, cabe señalar que, inicialmente, la reparación del daño moral fue rechazada en sede contractual. Este rechazo se fundó, principalmente, en una lectura restrictiva de las normas que regulan esta materia:

- Artículo 1556 CC, sólo se refiere al daño emergente y al lucro cesante (categorías indiscutiblemente de daño material), lo que se interpretará como una exclusión legal del daño moral en sede contractual.
- Ausencia de una norma como el 2329 que alude a “todo daño”.
- Adicionalmente se agregaba su difícil prueba y evaluación.

Progresivamente se fue aceptando legal y jurisprudencialmente. Desde la década de los 90, el daño moral es reparado en sede contractual, en base a los siguientes argumentos.

- Evolución jurisprudencial en el derecho comparado.
- Ante falta de norma legal, el juez debe llenar de acuerdo a los principios generales del derecho y la equidad natural.
- Art. 1556 no lo prohíbe. Por el contrario, es explicable porque al momento de la redacción del CC no existía la concepción de DM.
- En sede extracontractual existe la misma dificultad probatoria.
- Hermenéutica a la luz de la Constitución: Art. 19 nº1 (derecho a la vida y a la integridad física y psíquica) y 4 (respeto y protección a la vida privada y a la honra de su persona y su familia) CPR.
- Injusticia en tratado diferenciado de la víctima ante un mismo daño, según si exista o no un vínculo contractual previo entre ella y responsable.

b. Concepto de daño moral

No existe un concepto único de daño moral, y como hemos visto, es una institución cuyo alcance ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo.

Una concepción clásica de daño moral es aquella que lo limita al “pretium doloris” o precio del dolor. Conforme esta perspectiva, se puede definir el daño moral como “las aflicciones, pesares, molestias y sufrimientos que experimenta un individuo en su esfera psíquica a causa de la comisión de un hecho ilícito”.

Una concepción más moderna del daño moral amplía su espectro, identificándolo con todo perjuicio cuyo objeto no es un interés patrimonial. Así, se puede definir al daño moral como “todo daño privado que no puede comprenderse en el daño patrimonial

aplicación en la jurisprudencia nacional ya que, existiendo el daño moral, la reparación va a ser fijada de manera discrecional por el juez.

por tener por objeto un interés no patrimonial, osea, que guarda relación a un bien no patrimonial”.

En este último sentido, la Corte Suprema ha indicado: “La noción del daño moral ha avanzado a una comprensión más amplia que el mero padecimiento psicológico o pretium doloris, debiendo entenderse a partir de la fractura al proyecto de vida de la persona en razón del accidente lo que impacta en la esfera de la personalidad de la víctima.” (CS, Diciembre 2016)

c. Tipos del daños extrapatrimoniales

Como veíamos, el daño moral transitó desde una concepción limitada a los sentimientos de una persona hacia una lista cada vez mayor de intereses extrapatrimoniales jurídicamente relevantes.

A continuación, algunos tipos de daño extrapatrimonial. Es menester subrayar que siguiente lista no es exhaustiva, y la aplicación de los tribunales es variable:

- **Pretium doloris:** perjuicio de sufrimiento.
- **Perjuicio estético:** sufrimiento de una alteración peyorativa de su aspecto externo, visible y permanente.
- **Perjuicio de agrado:** perjuicio experimentado al no poder desarrollar las mismas actividades que podía ejercitar antes del accidente.
- **Perjuicio de afección:** carga emocional derivada de la lesión o pérdida de un ser querido (que sería pretium doloris cuando lo sufre una víctima indirecta).
- **Perjuicio sexual:** pérdida experimentada por aquel que a consecuencia del perjuicio corporal queda impedido de realizar el acto sexual y de procrear.
- **Perjuicio juvenil:** pérdida de potencial de capacidad laboral sufrida por un menor, así como la privación de algunas capacidades físicas.

d. Función de la indemnización del daño moral

La indemnización por daño moral presenta caracteres diferentes a la que se concede por daños patrimoniales que, según se ha dicho, persigue recomponer, mediante una reparación en dinero, la situación patrimonial que tendría la víctima de no haber ocurrido el accidente.

Tratándose del daño moral o extrapatrimonial, en cambio, aquello que se pierde o deteriora no tiene un valor de intercambio que pueda servir para reparar la pérdida por equivalencia. En este caso, la indemnización sólo puede tener una función satisfactiva del daño con un beneficio, reconociendo una ventaja pecuniaria a quien ha debido

soportar esa carga, y no una función reparatoria, como en el caso de la indemnización de perjuicios por el daño patrimonial.

La indemnización del daño moral tiene, entonces, naturaleza compensatoria del mal: éste no puede ser propiamente reparado, en la medida que, a diferencia de lo que ocurre con los daños patrimoniales, no es posible restituir a la víctima a la situación en que se encontraba antes de sufrir el accidente⁵⁶.

En este sentido, se ha señalado que el dinero no es equivalente del daño sufrido, sino una compensación, dando a la víctima una posible satisfacción que ponga a su alcance otros medios que atenúen la pérdida sentida.

e. Avaluación del daño moral: El baremo del poder judicial

La determinación de la cuantía de la indemnización por el daño moral es una tarea que queda entregada a los jueces. No obstante, por sus características propias, la avaluación del daño moral es una materia sumamente compleja. En efecto, tanto la valoración de los intereses jurídicos de carácter extrapatrimonial como la avaluación de las lesiones y menoscabos a los mismos obedecen a criterios más bien subjetivos.

El carácter subjetivo que, en principio, presenta la avaluación del daño moral es sumamente problemática, pues abre el riesgo a la existencia de fallos arbitrarios en cuanto a los criterio de la determinación de la indemnización, de fallos contradictorios respecto a circunstancias similares y, en último término, a la incertidumbre jurídica en materia de cuantificación del daño moral. Para hacerse cargo de este problema, y para tender a consolidar una jurisprudencia uniforme y coherente en la avaluación del daño moral, el Poder Judicial dispuso la creación de un baremo jurisprudencial estadístico acerca de la indemnización por daño moral.⁵⁷

Dicho baremo incorpora una serie de criterios por medio de los cuales es posible sistematizar la determinación del monto de indemnización en algunos casos paradigmáticos. Si bien el baremo no es vinculante para los jueces, sí les aporta una referencia objetiva para guiar su labor con criterios no subjetivos. De esta manera, poco a poco se han ido homogeneizando criterios en la jurisprudencia, y se observa una tendencia inicial a la 'objetivización' de la avaluación del daño moral.

⁵⁶ Una revisión detallada de la jurisprudencia nacional permite advertir que la indemnización del daño moral también ha tenido tradicionalmente una marcada función retributiva. Así lo demuestra el hecho que en la valoración de esta especie de daño usualmente sea considerada no sólo la entidad del daño sino también la gravedad de la culpa.

⁵⁷ El baremo puede ser consultado en el siguiente enlace: <https://baremo.pjud.cl/BAREMOWEB/>

f. Daño Moral Indirecto, Por Rebote o por Repercusión.

El daño moral indirecto, por rebote o por repercusión, es aquel daño moral que nace a consecuencia del perjuicio provocado a una víctima inicial de un hecho ilícito, y que afecta a personas diversas del sujeto inmediatamente perjudicado.

Sucede que, el hecho dañoso del cual es víctima una persona puede llegar incluso a afectar a terceros que, dado un especial vínculo o relación determinada han visto en el sufrimiento de la primera un solo simular que les puede llegar a causar un perjuicio a las segundas.

El daño por repercusión se plantea principalmente en los casos de *lesiones corporales y muerte de la víctima inicial*, pues además del evidente daño sufrido de forma directa en su persona y patrimonio, éste se extiende además a su cónyuge, hijos y a otras personas que de él dependen o que con él se relacionan.

Ejemplo: Producto de un accidente, un niño queda tetraplético. El niño es la víctima inicial y puede demandar IDP patrimonial y moral. El daño del niño puede repercutir en su madre, quién sufre al ver a su hijo en dicho estado. Aquí, la madre es la víctima indirecta del hecho dañoso.

Si bien el daño moral por rebote proviene justamente de un dolor ajeno, el daño sufrido por los terceros es uno por completo distinto y pertenece total y exclusivamente a estos. Vale decir, existe un hecho dañoso, pero dos víctimas y dos acciones.

En el ejemplo planteado, tanto el hijo como la madre serían titulares de una acción de indemnización de perjuicios, por daños distintos, aunque provenientes del mismo hecho dañoso.

La gran problemática de este tipo de daños es limitar la titularidad de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral indirecto, dada la desmesurada extensión que podría alcanzar el daño. La interrogante es: ¿quiénes pueden considerarse víctimas por repercusión o rebote?

g. Transmisibilidad del Daño Moral.

Es indudable que cuando la indemnización se funda en un daño patrimonial, la acción de indemnización de perjuicios es transmisible y que los herederos reciben, en el haz hereditario, la acción para reclamarla. Esto se puede deducir del artículo 2315, pero incluso si no existiera esta norma, la materia no es particularmente conflictiva pues el derecho a la indemnización patrimonial es naturalmente transmisible, por no existir norma en contrario.

Sin embargo, cuando se trata de una indemnización por daño moral, surge el problema de que este tipo de daño es personal, correspondiendo exclusivamente a la víctima. Así, surge la discusión acerca de la transmisibilidad del daño moral.

En relación con esta discusión, se han esbozado tres tesis⁵⁸: i) la intransmisibilidad absoluta del daño moral; ii) la transmisibilidad mitigada o limitada de la acción; iii) la tesis favorable a la transmisibilidad de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral.

i) Argumentos a favor de la Intransmisibilidad:

- La indemnización de perjuicios por daño moral está estrechamente ligada a ciertos bienes intangibles de la persona, por lo que debe considerarse un derecho personalísimo, y en consecuencia, no es transferible ni transmisible. En otras palabras, el crédito generado por el daño moral es tan personal como el derecho quebrantado.
- La finalidad de la indemnización de perjuicios por daño moral no es volver a las cosas al estado anterior del ilícito, lo que no es posible; su función es paliar las consecuencias del daño moral con una cantidad de dinero que la víctima puede utilizar para realizar actividades agradables que la ayuden a sobrellevar su pesar. Así, si los herederos ejercen la acción por el daño moral, la función compensatoria del daño moral se desvirtúa.
- El artículo 2315 del CC se aplica solo al daño patrimonial, por su texto y por cuanto a la época de redacción del CC no se concebía la indemnización de perjuicios por daño moral.
- La tesis de la transmisibilidad puede dar origen a situaciones absurdas o indeseables, como por ejemplo sea el Fisco quien percibe la indemnización (como heredero abintestato), o que lo sea un heredero testamentario que no tiene relación conyugal o familiar con la víctima.
- Adicionalmente, podría darse una situación de enriquecimiento sin causa, en la cual los familiares herederos puedan recibir una doble indemnización: como sucesores del ofendido y como titulares de un daño propio por repercusión, como víctimas indirectas (daño por rebote).

ii) Posición de la transmisibilidad mitigada

- Esta tesis parte de la intransmisibilidad, pero admite la posibilidad de que el crédito se transmita, solo en los casos en que el perjudicado expresó en vida su

⁵⁸ Para este paneo de las tesis disponibles en doctrina, seguimos el criterio de Susana Espada y Alberto Pino, contenido en un artículo titulado *La transmisibilidad del crédito indemnizatorio por daño moral de la víctima fallecida: Análisis del caso chileno*, publicado el año 2020 en la Revista Universitas, vol. 69.

voluntad de ejercitar la acción reparatoria o, si la ejercitó, falleció en el transcurso del proceso antes de que se le reconociera el crédito.

- En el fondo, esta tesis comparte la posición de la intransmisibilidad en el sentido de que, por su carácter personalísimo, el daño moral no sería transmisible. No obstante, una vez que se ha ejercitado la acción, esta se patrimonializa, y se vuelve transmisible según las reglas generales de la sucesión procesal.

iii) Argumentos a favor de la Transmisibilidad (Alessandri):

- Si bien el daño moral es personalísimo, de ello no se deriva que la acción para reclamarlo sea intransmisible. En efecto, todo daño es personal y ello no implica que no pueda ser transmitido. Aunque haya sido generada por la infracción a un interés extrapatrimonial y de carácter personalísimo, el crédito indemnizatorio generado por el daño moral es patrimonial, ha ingresado al patrimonio de la víctima desde el momento en que se produce el daño y, por lo tanto, sigue las reglas generales en materia de transmisibilidad.
- La regla general es la transmisibilidad de las acciones. La intransmisibilidad es excepcional, y no existen normas para señalar que la acción de indemnización de perjuicios por daño moral sería intransmisible. El legislador ha señalado expresamente cuales son los derechos intransmisibles.
- El propósito compensatorio de la acción de indemnización de perjuicios por daño moral no se ve desvirtuado, sino que se mantiene: pago de una cantidad de dinero que refleje el daño ocasionado.
- El artículo 2315 no discrimina entre el carácter de la indemnización.

Jurisprudencialmente, ha existido una interesante evolución, de recientes actualizaciones:

- Hasta el año 2012, la tesis imperante era la de la transmisibilidad.
- El 2012 se asienta la postura de la intransmisibilidad, la cual surge primeramente en el ámbito de accidentes del trabajo, pues la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales señala que la acción de indemnización de perjuicios por daño moral es personalísima. La postura de la intransmisibilidad se extiende a otras materias con el transcurso de los años.
- A finales del 2016, la cuarta sala de la Corte Suprema, a través de una sentencia de unificación de jurisprudencia (rol 33990-2016) redactada por Pizarro Wilson da un inesperado giro hacia la tesis de la transmisibilidad.

El caso consistía en un accidente laboral con resultado de muerte de un trabajador, en el cual la cónyuge sobreviviente y los hijos del difunto demandaron indemnización de perjuicios por daño moral sufrido por el trabajador contra el empleador. En 1era instancia y segunda instancia, la pretensión fue rechazada.

La Corte Suprema, sin embargo, dispuso: *“Que, por consiguiente, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina, en la especie,*

la posibilidad de los herederos de reclamar la indemnización del daño moral padecido por el causante, debiendo entenderse la acción transmisible (..)"

- El 1 de marzo de 2018, en sentencia rol 27842-2017, también se acogió la transmisibilidad del daño moral.

En el considerando 6º de dicha sentencia se establece que: *"Por otra parte el examen de lo resuelto demuestra que los sentenciadores, adhiriendo al criterio de transmisibilidad del daño moral en caso de muerte subsecuente de la víctima directa, aplicaron correctamente el objeto de esa transmisión, refiriéndolo sólo a la indemnización del daño o quebranto moral que alcanzó a experimentar o sufrir la víctima directa antes de su fallecimiento y con algún grado de conciencia de ese detrimento, lo que probablemente aconteció al experimentar la impotencia y angustia de hundirse en la piscina y percibir el inicio de un proceso de asfixia hasta perder la conciencia."*

No obstante los dos fallos mencionados, aún no es posible determinar si se trata de un verdadero giro jurisprudencial, o si se mantienen como dos fallos aislados dentro de la línea más larga de predominio de la tesis de la intransmisibilidad.

2.4. CAUSALIDAD

Para que un hecho doloso o culpable genere responsabilidad, es necesario que entre éste y el daño exista una relación o vínculo de causalidad⁵⁹.

La pregunta por la causalidad como requisito de la responsabilidad presenta en el derecho civil un fundamento de justicia correctiva: aceptado que alguien ha cometido un ilícito ¿hasta dónde llegan las consecuencias dañinas de ese acto que el autor debe soportar, descargando, en consecuencia, a la víctima de la responsabilidad?

Por lo general, la pregunta por la causalidad resulta extremadamente simple. Así, la colisión de dos vehículos porque uno de ellos cruza con luz roja o las lesiones sufridas por un transeúnte por la caída de un objeto desde un edificio en construcción, usualmente no presentan problemas de causalidad. En tales casos, la relación entre el hecho y el daño es de tal modo necesaria y directa que la causalidad puede darse por establecida sin dificultad. Así, por más que entre el hecho de infringir una norma del tránsito, como la que obliga a detenerse frente a la luz roja, y la muerte por anemia de la víctima de la colisión, actúen innumerables hechos intermedios (que el automóvil no pudo ser detenido, que se deslizó por la calzada, que embistió a otro automóvil, que el otro conductor sufrió una herida, que entre el accidente y los primeros auxilios

⁵⁹ Las normas del Código Civil no hacen referencia expresa a este requisito, aunque lo suponen. Así, los artículos 1439 y 2314 se refieren al hecho, constitutivo de delito o cuasidelito, que ha *inferido* daño, y el artículo 2329, señala que todo daño que pueda *imputarse* a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.

transcurrieron algunos minutos, etc.), la muerte es atribuible sin mayor dificultad al hecho culpable.

En verdad, la causalidad se presenta como un problema complejo sólo en situaciones límites y, por lo mismo, excepcionales, ya sea porque han actuado simultáneamente varias causas para ocasionar el daño o porque entre el hecho y el daño han intervenido circunstancias que alteran el curso normal de los acontecimientos.

El análisis del elemento de causalidad supone la satisfacción de dos presupuestos. Por un lado, se debe cumplir un elemento naturalístico, consistente en que un daño determinado sea una consecuencia necesaria de un hecho. Además, es necesario que entre ese hecho y el daño exista una relación directa.

De esta manera, la causalidad actúa, como requisito de la responsabilidad civil y como límite. Como requisito, exige que el hecho sea condición necesaria del daño. Como límite, pues no basta una relación puramente descriptiva, sino que además exige una apreciación normativa que permita calificar el daño como una consecuencia directa del hecho ilícito.

A continuación se analizarán ambos aspectos de la causalidad⁶⁰.

2.4.1 ELEMENTO NATURALÍSTICO: EL HECHO COMO CONDICIÓN NECESARIA DEL DAÑO

Tradicionalmente, la doctrina y jurisprudencia han estimado suficiente para dar por acreditada la causalidad que el hecho sea una condición *necesaria* del daño, sin el cual éste no se habría producido, aunque concurrieren otras causas.

Esta doctrina se conoce como de la *equivalencia de las condiciones o condictio sine qua non*. Todas las causas son equivalentes, en la medida que individualmente sean condición necesaria para la ocurrencia del resultado dañoso. Así, un daño tendrá tantas causas como hechos hayan concurrido para su ocurrencia. Para determinar si un hecho es condición necesaria basta intentar su *supresión hipotética*. Si eliminado mentalmente el hecho, el daño no se produce, de ello se sigue que tal hecho es causa necesaria de ese daño. Al revés, si suprimido el hecho, el daño igualmente se habría producido, la causalidad no puede darse por establecida.

Aplicando este criterio, si en la producción del daño han intervenido como condición necesaria otros hechos ilícitos atribuibles a terceros, la persona obligada a indemnizar

⁶⁰ A menudo la exigencia de que concurren elementos naturalísticos y normativos para dar por establecida la causalidad, ha sido planteada como una disputa entre dos doctrinas o teorías que pretenden explicar el requisito de la relación causal. En verdad se trata de dos preguntas diversas, que conviene plantear por separado.

podrá repetir contra sus autores por la parte que a cada uno corresponda, pero frente a la víctima estará obligada a responder íntegramente por el daño causado.

El establecimiento del hecho como condición necesaria del daño es un requisito mínimo para dar por establecida la causalidad, permitiendo excluir la responsabilidad en aquellos casos en que no existe conexión natural alguna entre el hecho culpable y el daño. Sin embargo, la causalidad relevante para el derecho no se agota en ese elemento naturalístico, sino exige, además, que el daño sea *directo*⁶¹.

El derecho civil no acepta hacer a alguien responsable de las consecuencias excesivamente remotas de sus actos, según el principio establecido por el artículo 1558 del Código Civil. Aunque esta norma se refiere a la responsabilidad contractual, la doctrina en general está de acuerdo en que establece un principio general de la responsabilidad civil, en orden a que sólo se responde de los *daños directos*. Y ocurre que para calificar un perjuicio como *directo*, no basta el test de la causa necesaria pues este no permite discriminar entre una relación causal *relevante* a efectos de la responsabilidad, y la que no lo es.

2.4.2 ELEMENTO NORMATIVO: EL DAÑO COMO CONSECUENCIA DIRECTA

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, según se ha expresado, están de acuerdo en que el daño resarcible sólo es el *directo*.

La pregunta acerca de si un daño es directo o indirecto supone un juicio normativo respecto de si *el daño puede ser objetivamente atribuido al hecho*. No es propiamente un juicio de causalidad (materia que se agota en el análisis que propone la doctrina de la equivalencia de las condiciones), sino una cuestión normativa que obliga a discernir cuáles consecuencias derivadas causalmente del hecho ilícito resultan relevantes a efectos de dar por establecida la responsabilidad. Por eso, las preguntas por la causalidad en sentido estricto y por las condiciones para calificar el daño como directo exigen dos pasos intelectuales sucesivos: establecido que un daño tuvo por causa necesaria un hecho ilícito, resta aún saber si normativamente ese daño puede ser *atribuido* a ese hecho ilícito.

La exigencia de que el daño sea directo cumple la función de discriminar entre todas las consecuencias dañinas de un hecho aquéllas que pueden ser atribuidas al ilícito, estableciendo así un *límite a la responsabilidad*. Ello supone que el juez aplique un

⁶¹ Para entender por qué el elemento naturalístico no es suficiente, basta analizar el famoso ejemplo propuesto por POTHIER, en sede contractual, del agricultor que ha comprado una vaca enferma y sufre la muerte de su ganado a consecuencias del contagio, de lo cual, a su vez, se sufre su ruina económica. En este caso no parece razonable concluir que la enfermedad de la vaca sería causa de esa ruina.

criterio normativo y no puramente descriptivo. Así, por mucho que se trate de un concepto indeterminado, la definición de lo que se habrá de tener por daño directo no puede ser arbitraria. Por eso, a diferencia del establecimiento de la relación causal en un sentido natural, la calificación del daño como directo es un juicio que queda sometido al control jurídico por vía de casación.

A continuación serán brevemente expuestas las principales *doctrinas jurídicas* que pretenden formular esos criterios de limitación de la responsabilidad, excluyendo los daños remotos.

1) La razonable proximidad como criterio de atribución de los daños

El sentido común lleva considerar como directo el daño que tiene una *razonable proximidad* con el hecho ilícito.

Si la responsabilidad se redujera a las consecuencias inmediatas (esto es, a las que se producen en la víctima sin intervención de otras causas), su ámbito quedaría absurdamente restringido en perjuicio de las víctimas.

Como se ha mostrado en el *common law*, la idea de causa próxima, por si misma, no agrega criterio alguno para calificar cuáles consecuencias del hecho son remotas, a efectos de establecer el límite externo de la responsabilidad. A falta de otros criterios coadyuvantes, la idea de causa próxima nada agrega a la exigencia genérica y vaga de que el daño sea *directo*.

2) Exigencia de una causalidad adecuada

La doctrina de la causa adecuada, que tuvo su origen en la dogmática alemana, se ha mostrado como un criterio iluminador para la atribución del daño al hecho culpable.

Según la doctrina de la causa adecuada, la atribución de un daño supone que el hecho del autor sea generalmente apropiado para producir esas consecuencias dañosas. Si desde la perspectiva de un observador objetivo, la ocurrencia del daño es una consecuencia verosímil del hecho, entonces se puede dar por establecida una relación de causa adecuada (y el daño, en nuestro lenguaje, resulta ser directo) y habrá lugar a la responsabilidad⁶².

⁶² Utilizando el ejemplo de Pothier podríamos señalar que la venta de una vaca enferma no es generalmente apropiada para producir la ruina de una persona desde la perspectiva de un observador externo.

Para esta doctrina, la causa no es adecuada cuando responde a factores intervinientes que resultan casuales, porque según el curso natural de los acontecimientos con posterioridad al hecho resultan objetivamente inverosímiles en la perspectiva de un observador imparcial.

La doctrina de la causa adecuada incluye un elemento de previsibilidad⁶³, en la medida que las consecuencias que escapan al curso normal de los acontecimientos son precisamente aquéllas con cuya ocurrencia no se puede contar, según la experiencia general de la vida. Es por esto que se ha señalado que la causalidad es dependiente de nuestra experiencia: entre todas las condiciones necesarias para la producción de un cierto resultado, hay algunas que, de acuerdo a la experiencia disponible, son capaces de causar el resultado.

La teoría de la causalidad adecuada deja, todavía, pendiente un problema, a saber, el problema consistente en determinar si acaso la experiencia con arreglo a la cual ha de juzgarse la adecuación es la experiencia del sujeto en concreto, o la experiencia disponible para un sujeto medio, en abstracto. Para Peña y Pizarro, este problema debe resolverse a favor del punto de vista abstracto, puesto que, de lo contrario, podría confundirse la experiencia del sujeto con la culpabilidad.

3) Atribución del daño resultante según el criterio del riesgo creado por el hecho

Lo determinante según esta variante es si el observador razonable habría tenido el correspondiente comportamiento por *riesgoso*, en tanto *aumenta el peligro de que surjan daños subsecuentes*. Si éstos efectos dañinos pueden ser interpretados como realización del peligro creado por el demandado, tales daños podrán ser objetivamente atribuidos al hecho y habrá lugar a la indemnización. Sólo si la acción u omisión culpables han creado un riesgo o han aumentado la probabilidad o la intensidad de un riesgo de daño ya existente, hay una relación relevante entre el hecho y el daño que resulta de él.

⁶³ Una importante dificultad que plantea la doctrina de la causa adecuada se refiere a que introduce también en sede la atribución objetiva del daño al hecho ilícito un elemento de previsibilidad que, como se ha visto, la jurisprudencia ya ha considerado en sede de culpabilidad. La previsibilidad aparece como elemento de la culpa en la medida que el cuidado debido es función precisamente del peligro de daño que envuelve la acción u omisión. En sede de causalidad, la previsibilidad tiende a reaparecer al momento de juzgar cuáles daños subsecuentes al daño inicial pueden ser atribuidos a la acción. Para ello, la doctrina de la causa adecuada recurre a la figura del observador externo que debe juzgar *ex post* cuáles daños pertenecen al desarrollo natural de los acontecimientos y cuáles a circunstancias extraordinarias que alteran sustantivamente el curso causal e impiden efectuar esa atribución.

El límite externo de los daños secuenciales comprendidos en la indemnización se alcanza cuando, atendidas las circunstancias, el daño debe ser objetivamente atribuido a los *riesgos generales de la vida* y no al riesgo creado o aumentado por el hecho que genera responsabilidad. En consecuencia, no será atribuible al hecho el daño que resulta de un hecho casual, de aquéllos que nos amenazan en el curso ordinario de nuestra existencia⁶⁴.

La idea de riesgo creado es en la práctica excluyente de otros criterios de atribución del daño en materia de *responsabilidad estricta u objetiva*. En esta sede el principio de responsabilidad es precisamente la atribución a quien realiza una actividad sujeta a ese régimen de responsabilidad de todos los daños que pueden derivarse de ella. En la medida que el daño materialice un peligro creado o aumentado por esa actividad hay lugar a la responsabilidad, con prescindencia de otros factores de atribución. A diferencia de la doctrina de la causa adecuada la doctrina del riesgo no discrimina entre los riesgos que pertenecen al curso normal de los hechos y los hechos que son exorbitantes, sino atribuye objetivamente a la acción todos los riesgos derivados de su ejecución, con el sólo límite de los daños que ya no pueden ser razonablemente atribuidos a esa actividad, porque pertenecen a los riesgos generales de la vida.

4) El fin de la norma

La atribución según el fin protector de la norma se basa en la idea de que toda obligación contractual o legal sirve determinados intereses y que sólo los daños que afectan estos intereses pueden ser atribuidos a quien realizó el hecho culpable.

El enfoque de la doctrina de la conexión de ilicitud es esencialmente concreto (a diferencia de las doctrinas del riesgo y de la causa adecuada): se indaga si la norma de conducta infringida tiene por fin evitar precisamente los daños ocurridos⁶⁵.

⁶⁴ Por mucho que la idea de riesgo agrega un punto de vista nuevo a la doctrina de la causa adecuada, tampoco conviene generalizarla. Si un conductor sobrepasa a una velocidad superior a la permitida a otro quien, sorprendido, sufre una sobreexcitación nerviosa que le provoca un infarto mortal, se puede afirmar que la muerte responde a un riesgo que ha sido creado por el conductor que conducía a 120 km/hora. Sin embargo, si se valora la situación puede resultar excesivo atribuir a este último ese riesgo. Del mismo modo, pareciera que son distintos el sobresalto emocional que sufre el padre que presencia el atropello de su hijo y el sufrido por un extraño que observa el accidente en televisión. En otras palabras, para definir qué riesgos son atribuibles, la idea de causa adecuada, que atiende a los efectos que ordinariamente pueden esperarse de un hecho, resulta en estas materias más ilustrativa que la mera consideración de la fuente del riesgo.

⁶⁵ Un antiguo caso del *common law* resulta ilustrativo a este respecto: el propietario de un barco transportaba, contra la reglamentación vigente, ganado en la superficie del velero; durante el trayecto el barco enfrenta una tempestad, a cuyas resultas el ganado se pierde en el mar; en el juicio se probó que la regla infringida fue establecida con el fin de evitar la difusión de plagas

El criterio de la conexión de ilicitud entre el hecho y el daño está recogido en nuestra Ley del Tránsito, que dispone que “el mero hecho de la infracción no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor, si no existe relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido por el accidente” (Ley Nº18.290, artículo 171).

Se ha señalado que no hay responsabilidad si el fin de la norma infringida no es proteger a la víctima del accidente, que la regla cautele intereses distintos a los invocados por el demandante, o si el riesgo que se persigue prevenir es diferente al materializado en el accidente.

2.4.3 PLURALIDAD DE CAUSAS O CAUSAS CONCURRENTES

Bajo las reglas de la causalidad, puede haber pluralidad de responsables en tres circunstancias: 1) cuando existen varios responsables que actúan simultáneamente ejecutando un mismo hecho (situación análoga a la coautoría penal); 2) cuando existen varios responsables por hechos distintos, todos los cuales son antecedentes necesarios del daño (por ejemplo, el caso del peatón víctima de un accidente de tránsito ocasionado por la negligencia concurrente de dos conductores); o bien, 3) cuando cada hecho individualmente es apto para producir el daño con independencia del otro hecho (causalidad aditiva).

1) Varios responsables por un mismo hecho

Si un mismo hecho es atribuible a diversas personas todas ellas son solidariamente responsables, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil.

El Código Civil no contiene una norma general que regule las relaciones internas entre los coautores del daño frente a la obligación de indemnizar. En efecto, no resulta aplicable en materia extracontractual la regla de contribución a la deuda del artículo 1522, que establece una distribución entre los deudores en atención a su interés en la operación contractual que dio lugar a la obligación solidaria.

La ley, en sede extracontractual, sólo establece una norma especial en el artículo 2325, aplicable a la responsabilidad por el hecho ajeno. Según esta disposición, la contribución recae en el autor del daño, de modo que el tercero civilmente responsable tiene acción en su contra para obtener el reembolso de lo pagado. El reembolso procede

contagiosas; el tribunal eximió de responsabilidad al capitán porque el riesgo no estaba cubierto por la norma que establecía el deber de conducta.

a condición de que el autor del daño sea capaz⁶⁶, que no haya existido culpa personal de ese tercero civilmente responsable, y que éste no haya dado una orden al autor del hecho que le debía obediencia.

Para los demás casos no contemplados por esa regla especial es posible idear dos soluciones: se reparte la deuda entre los coautores por partes iguales⁶⁷, o se distribuye entre éstos en razón de la intensidad de su contribución a la consecuencia dañosa. Esta última solución parece preferible, pues resulta coherente con el principio de justa repartición de la contribución a la deuda, que opera cuando ha intervenido la culpa de la víctima, según el artículo 2330 del Código Civil.

2) Varios responsables por hechos distintos

También se plantea la hipótesis que existan varios responsables por hechos distintos cada uno de los cuales es causa del daño⁶⁸. En principio, a esta situación no se aplicaría literalmente el artículo 2317 del Código Civil, pues no se trata de un solo delito o cuasidelito, sino de hechos ilícitos distintos, que generan responsabilidad separadamente para sus autores.

Sin embargo, como el autor de cada hecho ilícito debe responder de la totalidad del daño, y la víctima en caso alguno puede obtener una indemnización que exceda el monto de los perjuicios efectivamente sufridos, es necesario dividir la responsabilidad entre los autores de los diversos hechos, en proporción a su participación en el daño. El efecto, en consecuencia, es análogo al del artículo 2317 que establece la solidaridad: cada autor será responsable por el total del daño, sin perjuicio de su acción contra los demás para obtener reembolso en proporción a sus respectivas participaciones⁶⁹.

⁶⁶ Si no es capaz no existe propiamente responsabilidad por el hecho ajeno a la que resultan aplicables los artículos 2320 y 2322, sino responsabilidad por el hecho propio.

⁶⁷ Esta solución es sostenida por Alessandri.

⁶⁸ Un ejemplo de esta hipótesis de concurrencia de causas, puede verse en el caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago por sentencia de 3 de junio de 1968, confirmada por la Corte Suprema [cas. forma y fondo], en el que la colisión de dos vehículos, cada uno guiado con infracción de las normas del tránsito, hizo que uno de ellos fuera lanzado sobre un jardín ubicado en el bandejón central, atropellando a dos menores que jugaban en el lugar. La sentencia condenó solidariamente a ambos conductores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil (RDJ, Tomo LXVI, sec. 4ª, pág. 21).

⁶⁹ Un caso particular en que concurren diversos hechos ilícitos como causa del daño, es el que ocurre cuando un tercero interviene en un contrato ajeno, alcanzando un acuerdo con una de las partes, que ocasiona el incumplimiento del contrato. Por una parte, el tercero que interviene comete un hecho ilícito extracontractual; por otro, la parte que no cumple el contrato preexistente comete un hecho ilícito contractual, y ambos hechos generarán para sus autores responsabilidad por el total del daño experimentado por la otra parte del contrato. Con todo, las indemnizaciones no pueden ser acumuladas, por que de ello se seguiría un enriquecimiento injusto para la víctima.

3) Causa difusa

Mayores dificultades presenta la causalidad difusa que se muestra cuando el daño se debió al hecho culpable de alguno entre varios candidatos a responsable, sin que resulte posible determinar cuál concretamente desencadenó esos efectos dañosos.

En Chile sólo se conocen las normas sobre responsabilidad difusa por ruina de edificios y caída de objetos, que establecen una regla de distribución de la responsabilidad, que constituye una excepción al principio de solidaridad del artículo 2317 (artículos 2323 inc. 2 y 2328 inc. 1).

La experiencia comparada muestra que estas situaciones de causalidad difusa pueden surgir en accidentes de importancia: choque múltiples, productos defectuosos, daños ambientales, entre otros. La regla de división de la responsabilidad, mientras no se pruebe a cual hecho en particular puede ser atribuido el daño, parece ser una solución razonable en estos casos, pues responde al mismo principio de atribución de los artículos 2323 y 2328 ya referidos, según un criterio de integración del vacío legal por analogía.

Concurrencia de la culpa de la víctima

El concurso de causas puede presentarse también porque el daño se debe en parte al hecho ilícito y en parte a la intervención culpable de la propia víctima. Usualmente, la culpa de la víctima contribuye a la ocurrencia del daño o colabora a aumentar su intensidad. Así sucede, por ejemplo, cuando ésta omite usar el cinturón de seguridad al conducir, a consecuencia de lo cual los daños ocasionados por el choque de otro vehículo son mayores a los que se habrían producido sin esta circunstancia.

La culpa de la víctima se mide con los mismos criterios que la culpa del autor, y puede corresponder a una conducta anterior o posterior al hecho, que respectivamente se expresa en una exposición imprudente al daño o en la omisión de medidas a su alcance para evitar o disminuir los efectos dañosos de la acción culpable.

Según las reglas generales, la culpa de la víctima debe ser probada por quien la alega. El efecto de la contribución de la culpa de la víctima en la ocurrencia o intensidad del daño es, según prevé expresamente el artículo 2330, la reducción proporcional de la indemnización. El juez deberá comparar la culpa del tercero y la culpa de la víctima, determinar la proporción que a cada una corresponde en el daño y reducir el monto de la indemnización. Los criterios para determinar la reducción son la intensidad relativa de las culpas o imprudencias y la intensidad de las causas. Desde una perspectiva económica, se deberán considerar los distintos incentivos para evitar el riesgo, en busca del nivel óptimo de cuidado.

Con todo, aún existiendo culpa de la víctima, si ésta no influye de manera alguna en la producción del resultado no procede aplicar reducción proporcional de la indemnización. Por el contrario, puede ocurrir que la culpa de la víctima intervenga de tal modo en el nexo causal, que el hecho ilícito inicial resulte insignificante, y en consecuencia, deje de ser considerado causa determinante del daño. En estos casos, nos deberá reducir el monto de la indemnización, sino que excluir la responsabilidad.

2.4.4 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA CAUSALIDAD

Exclusión de la causalidad por caso fortuito o fuerza mayor

En materia de responsabilidad extracontractual se aplica el mismo concepto de caso fortuito o fuerza mayor que rige en el ámbito contractual, contenido en el artículo 45 del Código Civil, que lo define como “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Sin embargo, mientras que en materia contractual la fuerza mayor actúa como un concepto distinto al de la mera ausencia de culpa, tratándose de la responsabilidad extracontractual, la cuestión es similar a lo que ocurre con las obligaciones de medio, pues la ausencia de culpa excluye la ilicitud. En consecuencia, basta probar la ausencia de culpa para eliminar la responsabilidad.

Por ello, la fuerza mayor no opera en sede de culpa sino de causalidad, pues aunque haya intervenido un acto culpable, el daño no resulta atribuible a ese acto culpable sino al caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo: si un automovilista cruza la línea continua y choca con otro, hay culpa infraccional, pero si tal infracción ocurrió porque trató de esquivar a un peatón (tercero que provocó la mala maniobra) o porque el automovilista sufrió un ataque cardíaco imprevisible, el evento determinante es un caso fortuito o fuerza mayor y no la culpa del agente directo.

Elementos del caso fortuito o fuerza mayor

- 1) *Irresistibilidad*: Lo que se exige es que se trate de un evento insuperable, que no sea posible evitar sus consecuencias.
- 2) *Imprevisibilidad*: El caso fortuito comienza donde cesa el deber de previsión. No se trata de algo absolutamente imprevisible, sino imprevisible para el autor del daño atendido el nivel de diligencia que le es exigible⁷⁰. Por tanto es un concepto

⁷⁰ Al igual que la culpa, el caso fortuito se determina en concreto pero se juzga en abstracto. Luego, lo que se trata es que el hecho sea imprevisible e irresistible para un hombre prudente colocado en idénticas circunstancias.

normativo: aquello que el autor no estaba obligado a prever⁷¹.

3) *Exterioridad*: El hecho debe ser externo a la esfera de acción del agente.

Efectos

La fuerza mayor o caso fortuito excluyen la causalidad, aún cuando haya intervenido la culpa de la víctima.

Prueba de la causalidad

Los hechos que den lugar a la relación causal deben ser probados por el demandante, porque se trata de aquellos invocados para dar por probada una obligación indemnizatoria (artículo 1698 CC). La carga de la prueba se extiende a la demostración de que el hecho es condición necesaria del daño (causa en sentido estricto) y a las circunstancias de hecho que permiten calificar el daño como directo (imputación normativa del daño al hecho)⁷².

Calificación jurídica

La jurisprudencia tradicionalmente ha entendido que la determinación de la causalidad es una cuestión de hecho, y como tal, privativa de los jueces del fondo.

Con todo, la causalidad sólo es una cuestión estrictamente de hecho en su primer aspecto, esto es, entendida como condición necesaria de la responsabilidad. Por el contrario, la atribución normativa del daño al hecho ilícito (daño directo) es una cuestión de derecho, y como tal, susceptible de ser revisado por la Corte Suprema mediante la casación en el fondo.

⁷¹ De esta manera es caso fortuito el reventón del neumático de un automóvil nuevo o el síncope de una persona sin antecedentes cardíacos, y no lo es, un temblor grado cinco a seis en la zona central de Chile.

⁷² La causalidad usualmente no presenta dificultades de prueba. En casos difíciles, sin embargo, no existe otra manera de probarla que las presunciones judiciales, especialmente cuando se trata de daños producidos por causas múltiples o que resultan de la aplicación de tecnologías complejas.

CAPÍTULO 3. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las acciones que surgen de un daño causado por un tercero tienen por objeto indemnizarlo o removerlo. La más frecuente acción que surge para la víctima es de naturaleza indemnizatoria, y tiene por objeto obtener su reparación por equivalencia. El derecho civil reconoce además las acciones tendientes a prevenir un daño contingente o hacer cesar un daño actual, que pueden acumularse a la primera.

3.1. ACCIONES PREVENTIVAS

En lo que respecta a las acciones preventivas, el Código Civil contempla la *denuncia de obra ruinosa*, en el título de las acciones posesorias (artículo 932), además de otras dos acciones en el título de la responsabilidad civil, una de carácter específico (artículo 2328, inciso 2) y otra de carácter genérico (artículo 2333). Conforme a su naturaleza, estas acciones se tramitan según las reglas del procedimiento sumario.

Con todo, tanto las acciones preventivas como las acciones para hacer cesar el daño (por mucho que se tramiten en juicio sumario) tienen una eficacia limitada atendida la dificultad de obtener que se conceda provisionalmente lo solicitado mientras el juicio se tramita. Por esa razón, en la práctica tienden a ser sustituidas por la acción constitucional de protección.

3.2. ACCIÓN INDEMNIZATORIA

1. Características

La acción indemnizatoria es personal, mueble, patrimonial y transmisible⁷³.

2. Objeto

El objeto de la acción indemnizatoria es la obtención de una compensación en dinero por el daño causado.

⁷³ En el caso de la demanda deducida por una madre legítima por la muerte de su hijo, la Corte Suprema ha señalado que “el derecho a ser indemnizado por un daño recibido es transmisible” y que “al darse lugar a la demanda, fundándose en que la acción para reclamar el daño producido por un cuasi delito civil corresponde, entre otros, al heredero del que sufrió el daño... no se ha infringido ninguna de las disposiciones legales últimamente mencionadas [las contenidas en los títulos XXXV del Libro III del Código Civil], sino que, en cuanto eran aplicables al caso, lo fueron debidamente” [sic]. Con todo, hay que señalar que en este caso el daño indemnizado consistió en la pérdida de la ayuda económica que la víctima del accidente proporcionaba a la demandante y, en consecuencia, se trató de una acción que pertenecía a la demandada a título personal y no como heredera (Corte Suprema, 28 de abril de 1930, RDJ, Tomo XXVII, sec. 1ª, pág. 822).

3. Sujeto activo

La acción pertenece a quien sufre **personalmente** el daño⁷⁴. Sin embargo, hay casos en que un mismo daño afecta a distintas personas, todas las cuales están igualmente calificadas para ejercer la acción. Al efecto se debe distinguir:

a. Daños en las cosas

Si el daño recae en una cosa, serán titulares de la acción tanto el dueño como el poseedor⁷⁵. Tendrán acción además todos aquellos que detentan otros derechos reales sobre la cosa, como el usufructuario, el habitador o el usuario, si el daño irroga perjuicio a sus respectivos derechos.

El mero tenedor no tiene derechos sobre la cosa, en consecuencia, no puede reclamar su valor en caso de pérdida o deterioro mediante acción directa. Sólo podrá accionar en ausencia del dueño y en tal caso se entenderá que lo hace a nombre de éste y no a título personal (artículo 2315 del Código Civil)⁷⁶.

Sin embargo, el mero tenedor está legitimado para ejercer la acción indemnizatoria como titular de un derecho personal que se ejerce sobre una cosa, como el arrendatario, por el perjuicio que experimenta su crédito⁷⁷.

b. Daño a las personas

⁷⁴ La jurisprudencia ha ratificado este principio. Así, se ha fallado "que la acción compete sólo a quién ha sufrido el daño, a la víctima de éste, que la intentará contra el autor material; y el monto de la reparación dependerá de la extensión del daño, porque es su resarcimiento el que determina el monto de la reparación" (Corte Suprema, 29 de noviembre de 1968, RDJ, Tomo LXV, sec. 4ª, pág. 323). En el mismo sentido, se ha resuelto que "la acción compete al perjudicado y éste debe intentarlo en contra del autor o autores materiales o de quien responde civilmente" [sic] (Corte Suprema, 3 de septiembre de 1974, RDJ, Tomo LXXI, sec. 4ª, pág. 266).

⁷⁵ Si el demandante no acredita en el proceso su calidad de dueño o poseedor de la cosa dañada será rechazada la acción civil (Quinto Juzgado de Mayor Cuantía de Santiago, 12 de agosto de 1968, RDJ, Tomo LXV, sec. 4ª, pág. 189).

⁷⁶ Se ha fallado que en este caso "hay una especie de representación legal como consecuencia de que la indemnización reemplaza en cierto modo a la cosa que el deudor debía restituir" (Corte de Apelaciones de Valparaíso, 16 de abril de 1970, RDJ, Tomo LXVII, sec. 4ª, pág. 88).

⁷⁷ Incluso, habrá casos en que el objeto preciso de la lesión sea un derecho personal, como ocurre en las hipótesis de *interferencia en contrato ajeno*, en las que un tercero con conocimiento de la existencia del contrato ejecuta actos que hacen imposible su cumplimiento, ocasionando un perjuicio al acreedor.

La regla general es que el titular de la acción sea la persona que sufre directamente la lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido. Así, la doctrina distingue dos categorías de titulares de la acción:

A) Titulares por derecho propio

1. *Víctimas directas*: Es aquel sujeto cuyo cuerpo o patrimonio experimentó directamente el hecho ilícito.
2. *Víctimas por rebote o por repercusión*: Son aquellas personas que experimentan un desmedro en razón de las relaciones afectivas o económicas que los ligan con la víctima directa.

Tratándose de daños patrimoniales, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido titularidad a todo aquel que recibía una ayuda económica de la víctima directa, aún cuando no tuviese derecho a ella, de la que resulta privado a consecuencia del accidente, como el caso del padre que pierde la ayuda pecuniaria y personal de su hijo.

En materia de daño moral, en cambio, la regla general es que sólo se concede acción a la víctima indirecta en caso de muerte, a condición de que se acredite un parentesco cercano con la víctima directa. Excepcionalmente, se concede acción para reclamar indemnización por el daño moral en caso de lesiones, cuando estas son de tal entidad que en los hechos imponen una obligación de cuidado que afecta la calidad de vida de la víctima indirecta. Tal es el caso del pariente de la víctima directa que debe hacerse cargo de su invalidez

B) Titulares por derivación:

Son los herederos o causahabientes. Cuando el heredero ejerce la acción indemnizatoria en calidad su de tal (y no, en cambio, esgrimiendo el daño propio) y con apoyo en el principio de continuidad, pretende que se repare el daño que se le ocasionó al causante. Por lo mismo, nada impide que la persona reúna en si dos acciones distintas, y que persiga dos indemnizaciones diferentes, las que no se excluyen recíprocamente. De tal manera, si se impide que el heredero ejerza ambas acciones, se estaría infringiendo el principio de la reparación íntegra.

Tratándose de daño moral, se ha planteado el problema de si la muerte instantánea de la víctima ocasionada por el accidente, genera o no para el heredero el derecho a que se le indemnice por el daño moral sufrido por su causante. Tratándose de la muerte como resultado de un accidente, cabe distinguir dos situaciones, a saber: la muerte se produce como consecuencia directa del accidente, mediando un lapso entre este y

aquella; o bien, la víctima muere como consecuencia directa y casi simultánea con el accidente. En el primer caso, todos aceptan que el causante antes de morir fue titular de la acción de reparación por daño patrimonial y moral. Los herederos pueden, en consecuencia, ejercer y sumar dichas acciones a las que puedan ejercer por derecho propio. En el segundo caso, Alessandri argumenta que la muerte instantánea no genera acción de reparación por daño moral. Para Peña y Pizarro, dicha solución presenta tres defectos:

- 1) En verdad, el accidente necesariamente debe haber antecedido a la muerte.
- 2) La tesis de Alessandri parece creer que el daño moral es estrictamente coincidente con el sufrimiento experimentado por la víctima, cuando, en rigor, el daño moral mira a derechos personalísimos (esferas intangibles de la personalidad que el derecho estima requeridas de protección).
- 3) La tesis de Alessandri presenta problemas desde el punto de vista de las funciones de la Responsabilidad Extracontractual. Si nos plegamos a la opinión del jurista chileno, sería más rentable para el victimario matar inmediatamente a la víctima que simplemente lesionarlo. Esto conduce a la creación de incentivos para preferir la muerte antes que las lesiones. Alessandri se defiende, señalando que la víctima prefiere una muerte instantánea antes que una larga agonía.

4. Sujeto pasivo

La regla es que a la obligación indemnizatoria quedan sujetos tanto el autor directo del daño, como sus herederos (artículo 2316 del Código Civil), sin perjuicio de los casos de responsabilidad por el hecho ajeno (tratados en los artículos 2320 y 2322 del mismo código).

También es sujeto pasivo de la acción el que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice, pero sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho (artículo 2316, inciso segundo)⁷⁸.

5. Extinción de la acción de responsabilidad.

La acción de responsabilidad se extingue, en general, por los medios de extinguir las obligaciones, pues su objeto es hacer valer una pretensión indemnizatoria.

⁷⁸ La acción es, en este caso, restitutoria de un enriquecimiento sin causa.

a. Renuncia de la acción

La renuncia es un acto de disposición que extingue la acción si es efectuada con posterioridad al hecho que genera la responsabilidad. La autorización que la víctima del accidente da con anterioridad a su ocurrencia, constituye técnicamente una causal de justificación, que opera como eximente de responsabilidad

b. Prescripción de la acción

El artículo 2332 del Código Civil señala: “Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en el plazo de cuatro años contados desde la perpetración del acto”. En relación con esta disposición, se han planteado diversas interpretaciones en lo concerniente al cómputo del plazo. Estas pueden sistematizarse de la siguiente forma:

- a) Interpretada literalmente, la disposición da a entender que es el hecho del demandado el momento que determina el comienzo del plazo de prescripción. El problema, empero, dice relación con las circunstancias en las que el daño se produce o manifiesta después de ejecutado el hecho –lo que es frecuente en ciertos ámbitos como en medio ambiente o en el ámbito sanitario–. Esta es la posición tradicional, mas se encuentra en retirada. Así lo avaló la jurisprudencia nacional.
- b) Ante esta posición, se ha argumentado que el cómputo de la prescripción debe realizarse desde la producción del daño. En efecto, el perjuicio solo puede ser contemporáneo o posterior al hecho que lo provoca y este, en tanto requisito esencial para hacer responsable al demandado, debe determinar el momento en que nazca la obligación indemnizatoria.
- c) Una tercera posición, por último, defiende la tesis según la que el plazo de prescripción debe computarse desde que el daño se manifiesta y pueda ser conocido por el responsable. Así, si la víctima, por circunstancias que no sean atribuibles a su descuido no ha estado en condiciones de conocer el daño o a su autor, no habría razón para entender que el plazo de prescripción haya comenzado a correr en su contra⁷⁹.

Por otro lado, se han planteado dudas en cuanto a la procedencia de la suspensión de la prescripción. En virtud del artículo 2524 las prescripciones de corto tiempo a que

⁷⁹ Este es el criterio adoptado por el legislador en la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en relación con las acciones derivadas del daño ambiental. “Artículo 63.- La acción ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental prescribirán en el plazo de cinco años, contado desde la manifestación evidente del daño”.

están sujetas las acciones especiales de ciertos actos o contratos “también corren contra toda clase de personas”, de modo que se ha entendido como una remisión tácita a la regla del artículo 2523 del mismo código que señala que “las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de personas, y no admiten suspensión alguna”.

Para una parte de la doctrina, la prescripción de la acción indemnizatoria estaría comprendida entre aquellas de corto tiempo a las que se refiere el artículo 2524 y, por consiguiente no cabría aplicar la suspensión. En opinión de fallos recientes, sin embargo, el plazo de prescripción se suspende, porque no se trata de actos o contratos sino de hechos jurídicos que dan lugar a responsabilidad. En la medida que la suspensión es una institución general de protección, y que las excepciones debieran ser interpretadas restrictivamente, resulta preferible esta última opinión.

CAPÍTULO 4. OTROS ESTATUTOS DE RESPONSABILIDAD

4.1. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LAS MUNICIPALIDADES

Evolución

Históricamente, el derecho público ha concebido al menos cuatro regímenes de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado:

- a) Según la doctrina de la inmunidad de jurisdicción, el Estado no es responsable. Esta doctrina tiene sus orígenes remotos en la idea de que el soberano establece el derecho pero no está sujeto a él. En la actualidad, resulta inaplicable por ser contraria a las normas constitucionales que rigen la materia (artículos 6, 7, 19 Nº7 letra i), y 38 de la Constitución Política).
- b) Un segundo sistema distingue entre los *actos de autoridad*, en los que se manifiesta el poder soberano del Estado y que en consecuencia, según la primera doctrina, no le generan responsabilidad, y los *actos de gestión*, que quedan sujetos al derecho común.
- c) Un tercer modelo de responsabilidad asume que el Estado es responsable por los actos de sus órganos o funcionarios, a condición de que éstos hayan actuado en infracción de un deber de cuidado (culpa en sentido civil), o se haya incurrido en una *falta de servicio* (defecto en el ejercicio de una función pública).
- d) Finalmente, el Estado puede responder según un sistema de responsabilidad estricta basado exclusivamente en la causalidad entre la acción u omisión del órgano y el daño ocasionado al derecho de una persona.
- e) El más general de los criterios de responsabilidad del Estado y de las municipalidades es la *falta de servicio*. El concepto tiene una connotación objetiva, análoga a la que ha adoptado el concepto civil de negligencia. Tanto en la responsabilidad por culpa, como por *falta de servicio* no basta la mera causalidad material para que haya lugar a la indemnización del daño. Se requiere además un juicio normativo, que en la culpa civil reside objetivamente en la conducta efectiva, que es comparada con el estándar de conducta debida; y en la *falta de servicio*, recae en el estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. La diferencia es sutil y, en la práctica, por lo general irrelevante; en especial, si se atiende a la evolución jurisprudencial de la responsabilidad civil del empresario y de las personas jurídicas, que, como se ha visto, de *lege ferenda*, ha pasado a ser esencialmente *vicaria* (esto es, estricta).

En cuanto a los supuestos y a la extensión de la responsabilidad del Estado se distinguen tres ámbitos, dependiendo de la forma en que éste actúa. Dichos ámbitos son los siguientes: (a) responsabilidad por los actos de la administración y de los

municipios; (b) responsabilidad por error judicial⁸⁰ y, (c) responsabilidad por actos legislativos.

4.2. RESPONSABILIDAD CIVIL PRECONTRACTUAL

1. Fundamento

Von Jhering desarrolló en el siglo XIX una doctrina de la culpa in contrahendo, en cuya virtud las partes de una negociación tienen deberes recíprocos que nacen en razón de las tratativas contractuales. En el derecho contemporáneo, la protección de la seguridad y de la confianza, ha provocado una expansión de los tópicos que comprende la protección de las partes en la fase previa al consentimiento contractual.

2. Naturaleza de la responsabilidad precontractual

Mientras que no hay consentimiento, no existen obligaciones contractuales entre las partes. Sin embargo, ya desde las negociaciones de un contrato, surgen para ellas ciertos deberes de cuidado, impuestos por el derecho, y cuya infracción puede derivar en responsabilidad precontractual, de naturaleza extracontractual.

En la determinación de los deberes de cuidado durante las tratativas preliminares se ha de ser cuidadoso, pues se encuentran en juego bienes jurídicos que, en principio, se contraponen: la autonomía de la voluntad como fuente generadora de obligaciones y la confianza debida⁸¹.

3. Deberes de cuidado y buena fe en la negociación contractual

- i. Deberes de protección o seguridad: se refieren a la integridad corporal y a la propiedad de la contraparte, por ejemplo, mediante el control de los riesgos de accidentes que puedan sufrir visitantes de un local comercial.
- ii. Deberes de lealtad: supone que en la negociación exista un propósito efectivo

⁸⁰ Este ámbito de la responsabilidad del Estado tiene un reconocimiento expreso en el artículo 19 N°7 letra i) de la Constitución Política que señala: "Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia". La jurisprudencia ha sido extremadamente exigente para dar por establecidos los supuestos de dicha responsabilidad, exigiendo en la práctica, aunque no de modo explícito, que se haya incurrido en culpa grave.

⁸¹ En el common law la idea de que cada parte vela en la fase precontractual por sus propios intereses se expresa en el principio *caveat emptor*, en virtud del cual corresponde al comprador comprobar lo que está adquiriendo.

- de celebrar un contrato.
- iii. Deberes de información.
- iv. Deberes de evitar la ineficacia del acto.
- v. Deber de negociar de Buena fe. Supone limitar el juego puramente estratégico por deberes mínimos de lealtad, posibles de esperar de un contratante honesto. Dichos deberes, sin embargo, no pueden ser definidos con precisión, porque la buena fe es un estándar abierto.

4. Casos que podrían engendrar responsabilidad precontractual

A modo de ejemplo podemos señalar:

- i. Responsabilidad por ilegítima de las negociaciones.
- ii. Responsabilidad consecuencias de la nulidad de un contrato.
- iii. Responsabilidad por infracción a deberes de seguridad.
- iv. Responsabilidad por infracción a deberes positivos de información.

4.3. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL

La responsabilidad civil y penal son independientes entre sí ⁸² : puede haber responsabilidad penal sin que exista responsabilidad civil (por ejemplo, si el hecho ilícito penal no ocasiona daños) y, a la inversa, es usual que los casos de responsabilidad civil no conlleven responsabilidad penal, como ocurre genéricamente cuando el hecho que ocasiona el daño no está tipificado como delito.

Con todo, estando sujeta la responsabilidad penal a requisitos más estrictos, la sentencia que se pronuncie en esa sede puede producir efectos en materia civil, lo que no ocurre en el sentido contrario⁸³. Por la misma razón, la ley atribuye competencia civil al juez penal respecto de ciertas acciones civiles⁸⁴, de la que, a la inversa, carece el juez civil.

⁸² Originalmente, ambos estatutos aparecían confundidos. La tendencia a la separación se ha acentuado en épocas recientes mediante la construcción de una teoría del delito extremadamente refinada, que se ha caracterizado por la definición rigurosa de los requisitos para hacer procedente la sanción penal, con el resultado de que la doctrina del delito actúa como un límite a la imposición de la pena. Además, la tendencia a separar las esferas de lo público y de lo privado, y a relegar a esta última amplios ámbitos de la moral, la religión y las costumbres, ha hecho que conductas que antes estaban sujetas a la regulación estatal por la vía penal, hayan sido entregadas al juicio individual.

⁸³ Conforme establece el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil: "En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo". A la inversa no ocurre lo mismo ya que, por regla general, las sentencias absolutorias penales no producen cosa juzgada en materia civil, a menos que se cumplan las condiciones señaladas en el artículo 179 del mismo Código.

⁸⁴ La víctima, y únicamente ella, podrá ejercer la acción indemnizatoria en sede penal, siempre que se dirija contra el imputado.

A continuación, analizaremos las principales diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal:

	Responsabilidad Civil	Responsabilidad Penal
Capacidad	Son absolutamente incapaces los menores de 7 años y los dementes.	Son absolutamente incapaces los menores de 14 años y los dementes.
Tipicidad	En la generalidad de los casos el tipo específico es determinado por el juez con posterioridad a la conducta que se juzga.	La conducta que se sanciona se adecue exactamente a la descripción del delito que contiene la ley (rige el principio de legalidad de la pena).
Culpa	Se aprecia en abstracto.	Se aprecia en concreto.
Daño	Si la acción culpable no genera daño, no existe responsabilidad.	Por regla general, no resulta necesario que se produzca un daño efectivo al bien jurídico protegido para atribuir responsabilidad, salvo que se trate de un <i>delito de</i>
Sujetos pasivos de la acción.	En materia civil, en cambio, las personas jurídicas son plenamente responsables.	En materia penal sólo son sujetos pasivos de responsabilidad las personas naturales personalmente responsables del delito.
Sujetos activos de la acción	La acción es esencialmente renunciante.	La regla general en materia penal es que la acción sea pública. Esta acción es irrenunciable.
Prescripción	En materia civil, en cambio, el plazo de prescripción es de 4 años, contados desde la perpetración del acto	En materia penal el plazo de prescripción de la acción varía dependiendo de la gravedad de la pena asignada al delito, y se cuenta desde la fecha de comisión del ilícito

4.4. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL

Según la opinión mayoritaria, el estatuto de responsabilidad contractual y el de responsabilidad extracontractual pertenecen a esferas distintas: mientras la responsabilidad contractual se origina en el incumplimiento de un contrato, la segunda tiene su fuente en un hecho que ocasiona un daño, sin que exista un vínculo previo entre el autor de ese daño y la víctima. Por ello, tradicionalmente se ha sostenido que

la responsabilidad contractual es de segundo grado, y la responsabilidad extracontractual de primer grado u originaria⁸⁵.

Principales diferencias entre ambos estatutos

	Responsabilidad contractual	Responsabilidad
Fuente	Se deriva de un incumplimiento contractual.	Nace de la infracción de un deber de cuidado.
Capacidad	La plena capacidad contractual o negocial se adquiere sólo a los 18 años.	Mientras en materia extracontractual son absolutamente capaces los mayores de 16 años, y los menores entre 7 y 16 años que hayan actuado con discernimiento.
Graduación de la culpa⁸⁶	Se aplica el artículo 44 CC.	Se responde de toda culpa, inclusive la levísima.
Mora	Se exige para que proceda la indemnización	No es un requisito de procedencia de la responsabilidad.
Extensión de la reparación⁸⁷.	Se aplica el artículo 1558 CC.	No se aplica.
Pluralidad de obligados	La regla general es que habiéndose contraído por muchas personas una obligación de cosa divisible, sus obligaciones se entienden simplemente conjuntas (artículo 1511 del Código Civil).	Existiendo varios obligados al pago de la indemnización, la responsabilidad entre ellos es solidaria (artículo 2317).

⁸⁵ Sin embargo, esta distinción no siempre ha sido aceptada. Con especial énfasis a mediados del siglo veinte, parte de la doctrina comparada se ha manifestado a favor de un tratamiento único de los dos estatutos de la responsabilidad civil, basándose para ello, entre otros fundamentos, en el rol cada vez más disminuido de la voluntad de las partes en la contratación moderna, crecientemente reemplazada por los deberes generales impuestos por los usos, la costumbre, la prudencia o la propia ley, llegando en algunos casos a afirmarse que no existe contratación propiamente tal, sino un conjunto de deberes de conducta establecidos por la ley. De ello resulta que los efectos del contrato no serían sustancialmente diversos de los que genera la comisión de un ilícito, lo que en definitiva haría improcedente la distinción entre ambos estatutos.

⁸⁶ Materia discutida, ver sección 2.2.1.

⁸⁷ Materia discutida, ver sección 2.2.1.

Prueba de la culpa	Por regla general se presume.	La víctima debe probarla.
Prescripción de la acción	La prescripción extintiva ordinaria es de 5 años contados desde que la obligación se haya hecho exigible (art. 2515 CC)	La prescripción extintiva es de 4 años contados desde la perpetración del acto (art. 2332 CC).

CAPÍTULO 5. CONCURSO O CÚMULO DE RESPONSABILIDAD

Bajo el concepto de *cúmulo de responsabilidad* la doctrina se ha referido tradicionalmente al problema de la concurrencia de los dos estatutos de la responsabilidad civil, en aquellos casos en que un mismo hecho importa a la vez el incumplimiento de una obligación contractual y la ocurrencia de un delito o cuasidelito civil.

Este problema se plantea con frecuencia en materia de responsabilidad profesional; en especial de los médicos, quienes en la mayoría de los casos están vinculados por un contrato y además por deberes específicos de cuidado relativos a la integridad física del paciente.

Lo primero a tener en cuenta, es que no es posible acumular ambas acciones de responsabilidad, porque ello se traduciría en un enriquecimiento sin causa de la víctima (que sería indemnizada por dos conceptos diferentes por un mismo daño).

La cuestión relevante es resolver si la víctima, ante la existencia de un hecho del que se siga ambos tipos de responsabilidad, puede optar por demandar según el estatuto que le resulte más favorable.

Tradicionalmente, la doctrina y la jurisprudencia nacional se manifiestan en contra de la opción entre ambos estatutos de responsabilidad. Según esta opinión, conceder la posibilidad de optar entre una u otra acción para reclamar la indemnización de los perjuicios importaría desconocer la obligatoriedad del contrato, que conforme al artículo 1545 del Código Civil, vincula a las partes con la misma fuerza que la ley.

A ello se agrega que en opinión mayoritaria de la doctrina la especialidad de la responsabilidad contractual prima sobre la responsabilidad extracontractual, a la que se asigna un carácter residual. Como se advierte, esta posición importa privilegiar el principio obligatorio del contrato, en virtud del cual los deberes generales de respeto recíproco (típicos de la responsabilidad extracontractual) ceden frente a la relación obligatoria consentida en el contrato.

Sin embargo, en opinión de la doctrina y de alguna jurisprudencia, bajo ciertas circunstancias la opción resulta excepcionalmente procedente. Desde luego que ello ocurre cuando así lo han estipulado las partes (por aplicación del principio de autonomía privada expresado por el artículo 1545 del Código Civil). También se acepta la opción cuando el incumplimiento del contrato constituye a la vez la comisión de un ilícito penal.

Presta relevancia el reciente fallo de la Exma. Corte Suprema, de fecha 21 de marzo del 2016, en que tratándose de un caso de responsabilidad médica acoge el derecho de opción del actor para elegir libremente el estatuto contractual o extracontractual.

En efecto el fallo concluye que la responsabilidad médica es un caso de difícil determinación en relación a su naturaleza jurídica toda vez que se contienen aspectos del estatuto contractual (existencia del contrato médico) y extracontractual (existencia de un daño producido producto de una negligencia). Establece que si bien, coexisten ambas responsabilidades “en verdad aunque con un tratamiento distinto por la dualidad con que las regula el ordenamiento jurídico, no dejan de tener la misma naturaleza, es decir, en cualquiera de las sedes anotadas, se trata de una acción indemnizatoria de perjuicios, donde existe un incumplimiento contractual y una violación a las reglas delictuales, llegando incluso parte de la doctrina a plantear una tesis unitaria de responsabilidad, bajo la premisa que hechos ilícitos e incumplimientos, son ambos manifestaciones de una actuación contraria al derecho, que da origen a la obligación de indemnizar”⁸⁸. Es por ello que nace para el acreedor la posibilidad de “opción de responsabilidades”.

Fundamenta este derecho a opción señalando que no existe una razón jurídica⁸⁹ para que pueda privarse a la víctima del derecho de opción del estatuto que utilizará al presentar una hipótesis de esta especie. Además, no existe perjuicio⁹⁰ alguno para el demandado toda vez que el término de prescripción en sede extracontractual es inferior al contractual y la carga de la prueba en ambos casos se radica en el demandante. Finalmente, y siguiendo a Enrique Barros, establece que “la tendencia comparada ha sido entender que los responsables, lo sean en virtud de un contrato o de un deber general de diligencia, hacen una contribución indivisible a la realización del daño dando lugar a una obligación reparatoria *in solidum*”⁹¹.

Cabe mencionar que el fallo mencionado no corresponde a un cambio jurisprudencial toda vez que, es muy reciente, no ha sido repetido por fallos posteriores, y ha sido objeto de críticas por su breve fundamentación.

⁸⁸ SCS, 21 de marzo de 2016, Rol: 31.061-2014, considerando séptimo.

⁸⁹ SCS, 21 de marzo de 2016, Rol: 31.061-2014, considerando octavo.

⁹⁰ Ídem.

⁹¹ SCS, 21 de marzo de 2016, Rol: 31.061-2014, considerando noveno, citando a Enrique Barros Bourie, “Tratado De Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica. Año 2006. Págs. 657 y 667 y 668.

El sistema de derecho común

Parte de la doctrina nacional (sobre todo ALESSANDRI), sostiene que el régimen común de responsabilidad es el contractual, pues es el único que está regulado genéricamente a propósito de los efectos de las obligaciones (artículos 1545 y ss. del Código Civil).

Sin embargo, la mayoría de los deberes de cuidado a que se está sometido en el tráfico no dan lugar a relaciones obligatorias. Por ello, en la práctica, el régimen común es el de responsabilidad extracontractual, pues se refiere precisamente a esas relaciones que no están regidas por vínculo obligatorio preexistente.

Esta discusión presta relevancia toda vez que, existen ciertos casos en donde resulta difícil la determinación de qué estatuto es el que se debe aplicar, como por ejemplo, en la responsabilidad precontractual, responsabilidad médica, declaración de nulidad de un acto por dolo, o en general, daños emanados por el incumplimiento de obligaciones emanadas de otras fuentes como los cuasicontratos y las obligaciones legales.

ANEXO I – EL PROBLEMA DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL DAÑO MORAL⁹²

Por diversos motivos –derivados principalmente de la concepción que se tiene del daño moral– la cuestión de la prueba del menoscabo no patrimonial, no ha sido estudiada en profundidad, dejando un sensible vacío en la materia, tanto más cuanto se trata de uno de los tópicos fundamentales al momento de llevar a la *praxis* jurídica las teorizaciones que sobre el particular se han elaborado.

Como punto de partida, podemos afirmar que, en materia de prueba del daño moral, la cuestión no es pacífica y, tal como ocurre con otros institutos que forman parte de la responsabilidad civil, no existe una única opinión que resuelva el tema. En efecto, es posible percibir que la doctrina en general se encuentra conteste en una máxima que debe regir el asunto: “el daño moral debe ser acreditado siempre”.

La jurisprudencia, por el contrario, ha sido contundente en afirmar que, dada la particular naturaleza de éste, el perjuicio no patrimonial no puede ser objeto de prueba o, en el mejor de los casos, debe ser presumido. Analizando desde esta perspectiva el problema, los jueces han tendido a excluir la exigencia probatoria del daño moral, por cuanto estiman que la dificultad que entrañaría la prueba del mismo haría imposible obtener una indemnización por esta partida para el afectado, ya que resultaría una quimera intentar acreditar el dolor experimentado, o el pesar o malestar que se ha padecido.

Como vemos, la posición que se adopte en torno al concepto de daño moral -en el caso de la jurisprudencia tradicional, la de *pretium doloris*– influirá en forma decisiva, tanto en el ámbito probatorio como en la avaluación del mismo. Sin perjuicio de lo señalado, es necesario señalar que existe también una línea jurisprudencial que ha ido ampliando la categoría del daño moral, conceptualizándola como una violación a un interés jurídicamente tutelado.

Carmen Domínguez Hidalgo ha prevenido sobre el particular, señalando que acceder a tal exclusión probatoria podría implicar abrir la ventana a conductas arbitrarias e injustas, potenciando y dando origen a sentencias disímiles, lo cual en definitiva sería un golpe a la justicia, y a la seguridad jurídica.

Recordemos también que la ley sólo en situaciones excepcionales ha llegado a presumir la existencia del daño, como ocurre en los casos de la clausula penal o en el caso del artículo 1559 del Código Civil, cuando sólo se cobran intereses en las obligaciones de dinero. De manera que, para todos los demás casos de daño, sean patrimoniales o extrapatrimoniales, la regla del artículo 1698 relativa a la carga de la prueba, se mantiene completamente vigente. En consecuencia, en materia del daño moral, el demandante debe acreditar todos los requisitos que funden su pretensión, siendo el menoscabo patrimonial uno de ellos.

⁹² Basado en “Notas sobre la prueba del daño moral en la responsabilidad civil”. Jorge Femenías Salas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile.

Por lo demás, al no existir una regla especial que limite los medios probatorios para este tipo de daños, caben todos aquellos señalados por la ley. En este estado de cosas, las partes podrán valerse para acreditar la procedencia –o improcedencia– del daño moral invocado por una de ellas, de la prueba documental, pericial, testifical, y la prueba en base a presunciones.

En la práctica, el mecanismo de la presunción del daño moral es perfectamente factible, en tanto sean las partes las que proporcionen al juez los hechos que le permitan, a partir de un hecho conocido (el hecho fáctico proporcionado por el actor), arribar a uno desconocido –y pretendido– como lo es, el daño moral que pueda haber sufrido el demandante, conforme se ha expuesto anteriormente.

ANEXO II – LOS DAÑOS PUNITIVOS

Los daños punitivos o *punitive damages* corresponden a una categoría desarrollada en las tradiciones jurídicas del *Common Law*, y que consisten en una indemnización de perjuicios cuyo monto no se limita al daño efectivamente sufrido por la víctima, sino que aumenta tomando en cuenta otros objetivos. Si bien en la doctrina nacional la figura ha tenido poco desarrollo, analizando las posiciones del derecho y la doctrina comparadas podemos decir que los principales objetivos de los daños punitivos son dos: i) Castigar a quien produce un mal de manera maliciosa o dolosa; ii) disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros eventuales infractores de cometer, nuevamente, conductas dañosas como la reprochada.

Tomando en cuenta lo anterior podemos ver que, por su naturaleza jurídica, los daños punitivos se encuentran más cerca de la idea de una pena privada que a la idea de una indemnización de perjuicios propiamente hablando, pues, en este último caso, el criterio de determinación del monto de la indemnización es el daño efectivamente sufrido. En este sentido, desde el punto de vista de los fines de la responsabilidad, los daños punitivos encuentran su fundamento directo en la noción de la justicia retributiva, pues buscan sancionar al autor del daño, tomando en cuenta la forma en que se cometió la infracción. En menor medida, los daños punitivos también pueden encontrar su fundamento en un criterio preventivo. En cambio, se alejan radicalmente de la noción de justicia correctiva, pues exceden el monto del daño efectivamente causado.

Precisamente por lo anterior es que los daños punitivos se han criticado fuertemente en doctrina. En primer lugar, se los critica por ser una fuente de enriquecimiento sin causa, toda vez que la víctima, al ser indemnizada por un monto superior al daño efectivamente sufrido, se estaría enriqueciendo a expensas del penalizado. En segundo lugar, se los critica por el amplio espacio que se le abre a la arbitrariedad judicial en la determinación de la pena, y a la incerteza jurídica que ello genera. Por último, algunos autores han llegado a sostener la inconstitucionalidad de los daños punitivos, pues la aplicación de penas en el proceso civil sería un atentado contra el debido proceso, y además porque, en ciertos casos, podría contravenir el principio del *non bis in idem*.

En nuestro ordenamiento jurídico, la figura de los daños punitivos no tiene cabida alguna. La regla del art. 2329 CC es muy clara al establecer el principio de la reparación

integral del daño, en virtud del cual el monto de la indemnización de los perjuicios debe corresponder precisamente a los daños causados. No obstante lo anterior, en la práctica, los jueces han tendido a tomar en cuenta otros factores en la determinación del monto de la indemnización de perjuicios por el daño moral, tales como el dolo o malicia con que ha actuado el autor del daño, las facultades económicas del ofensor o la posición de la víctima. De esta manera, en algunos casos, en la práctica los daños morales han tendido a adoptar una función punitiva. Es necesario acotar que esta práctica ha sido sumamente criticada en doctrina, principalmente por contravenir los artículos. 2314 y 2329 CC.

Por último es necesario tener en cuenta las modificaciones introducidas a la Ley de Protección a los derechos de los Consumidores (Ley 19.496) por la ley 21.081, promulgada durante el año 2018. En virtud de dicha modificación, el artículo 53 C de la ley 19.496 establece que, en la sentencia que se dicte acogiendo la demanda en el marco de un proceso para la protección de los intereses colectivos o difusos de los consumidores, el tribunal podrá aumentar en un 25% el monto de la indemnización correspondiente, si concurre alguna de las circunstancias previstas en el inciso 5º del artículo 24 de la misma ley. Dicho artículo 24 establece las siguientes circunstancias agravantes: a) el haber sido el proveedor sancionado con anterioridad por la misma infracción; b) el haber causado un daño patrimonial grave a los consumidores; c) el haber dañado la integridad física o psíquica de los consumidores o, en forma grave, su dignidad; o, finalmente d) en caso de haber puesto en riesgo la seguridad de los consumidores o de la comunidad, aun no habiéndose causado un daño.

Si bien la norma legal referida no acoge en términos explícitos el término daños punitivos, resulta evidente que ese recargo del 25% sobre el monto de la indemnización no obedece a consideraciones indemnizatorias, sino propiamente sancionatorias.

ANEXO III – LA ANTIJURIDICIDAD COMO REQUISITO DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

La regulación del Código Civil en torno a los requisitos necesarios para que se configure la responsabilidad extracontractual es más bien escueta. En efecto, solo contamos con las indicaciones genéricas contenidas en los artículos 2284, 2314 y 2329 CC. Así, ha sido la doctrina la que se ha encargado de sistematizar los requisitos de la responsabilidad extracontractual, tal como se explica en el cuerpo del apunte: i) la acción u omisión; ii) la imputabilidad a título de culpa o de dolo; iii) el daño; iv) la relación de causalidad. A pesar de que esa es la posición mayoritaria, algunos sectores de la doctrina postulan a la antijuridicidad como elemento autónomo de la responsabilidad extracontractual. En este anexo analizaremos los principales aspectos de esta posición doctrinal.

En primer lugar, es necesario constatar que la inmensa mayoría de la doctrina nacional no aborda el problema de la antijuridicidad del hecho dañoso. En general se ha estimado que el carácter contrario al derecho está dado netamente por la culpa o el dolo. Así, la doctrina tradicional no analiza la antijuridicidad como requisito de la responsabilidad extracontractual o, en el mejor de los casos, la subsume dentro de la culpa o el dolo. La propuesta de la antijuridicidad como elemento autónomo obedece a

una posición reciente, que ha sido defendida sobre todo por Pablo Rodríguez Grez y por Hernán Corral Talciani.

Para Rodríguez Grez, la antijuridicidad consiste en “la contradicción entre una determinada conducta y el ordenamiento normativo considerado en su integridad. En otras palabras, la conducta de la cual se sigue la responsabilidad es contraria a derecho”⁹³. Para Corral Talciani, un acto es antijurídico cuando dicho comportamiento es “objetivamente ilícito, contrario al ordenamiento, contrario a lo justo”⁹⁴. De la formulación de ambos profesores, podemos concluir que la antijuridicidad consiste en un juicio de valor objetivo, general y abstracto, que dice relación con la contradicción entre una conducta o hecho dañoso objetivamente considerado, y el ordenamiento jurídico. En virtud de esa contradicción, el derecho no tolera ese hecho dañoso, y lo sanciona con la obligación de indemnizar el daño causado.

Para quienes sostienen que la antijuridicidad es un elemento autónomo de la responsabilidad extracontractual, desde un punto de vista teórico resulta esencial la distinción entre el objeto de imputación y el factor de atribución en materia de responsabilidad. El objeto de la imputación es el hecho dañoso antijurídico o el injusto civil. En cambio, el factor de atribución por el cual es posible imputar la obligación indemnizatoria a quien comete ese hecho, es la culpa o el dolo. Así, no considerar la antijuridicidad como un elemento autónomo de la responsabilidad extracontractual implicaría confundir el objeto imputado con el factor de imputación.

Luego, desde un punto de vista práctico, esta distinción se vuelve más clara si tomamos en cuenta la forma en la que operan las causales de justificación. Las causales de justificación reconocidas por la doctrina mayoritaria (legítima defensa, estado de necesidad, los actos autorizados por el derecho, y el consentimiento de la víctima y aceptación de riesgos), son casos en los cuales el acto dañoso es tolerado por el derecho, de manera que operan excluyendo la antijuridicidad, aunque no excluyan necesariamente el dolo o la culpa. Por ejemplo, ante un caso de una persona que actúa dañando a otro para repeler un daño ilegítimo a su propia persona, puede invocar la causal de la legítima defensa para excluir la responsabilidad que se genere por dicho daño. Sin embargo, resulta claro que en este caso hay una intención de dañar a quien le hubiera inferido dicho daño. De esta manera, no puede decirse que la legítima defensa opere excluyendo el dolo, sino que opera excluyendo la antijuridicidad, pues el derecho tolera y ampara el daño ejercido en legítima defensa.

⁹³ Rodríguez Grez, Pablo (2010) “Responsabilidad extracontractual” 2º edición. Editorial Jurídica de Chile, p. 131

⁹⁴ Corral Talciani, Hernán (2013) “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual”. 2º edición. Editorial Legal Publishing, p. 111

ANEXO IV – LA RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LOS ANIMALES

Nuestro código civil califica jurídicamente a los animales como bienes muebles semovientes, conclusión que podemos desprender del artículo 567. Al ser bienes animados o semovientes, son capaces de provocar daños a terceros. Por lo mismo, el código regula dicha hipótesis y busca atribuir responsabilidad al dueño, tenedor, poseedor o quien se sirva del animal por los daños que el mismo provoque.

Nuestro código regula dichas hipótesis bajo el título bajo título XXXV del código civil y, en específico, en los artículos 2326 y 2327. Dichos artículos se hacen cargo de distintas hipótesis, y consagran distintos modelos de atribución de responsabilidad para cada una de ellas.

Lo primero, entonces, es indicar las distintas hipótesis que contemplan los artículos citados. El código nos invita a distinguir entre aquellos animales que se consideran fieros de los que no. Los animales fieros que no prestan utilidad al predio de quien los tiene, estarían sujetos al artículo 2327 CC, y el resto de los animales al art. 2326 CC. Como se señaló anteriormente, ambos artículos consagran dos modelos distintos de atribución de responsabilidad. Lo que respecta al art. 2327 -entiéndase a los animales fieros- supone una imputación objetiva a su dueño por los daños que estos provoquen a terceros. Así, dicho sistema prescinde del elemento de culpabilidad debido a la peligrosidad que suponen dichos animales.

Por su parte, aquellos animales que no son considerados fieros, y podríamos referirnos a ellos como animales domésticos, les es aplicable el artículo 2326, que consagra un modelo de atribución por culpa, pero con la particularidad de consagrar una presunción de culpa por el hecho de las cosas. En esta hipótesis no se prescinde del elemento de culpabilidad, sino que solo se altera el *onus probandi*, de forma tal que se presume que el dueño o quien se sirva del animal es el responsable del daño, salvo que él logre acreditar que *la soltura, extravío o daño no puede imputarse a su culpa*.

Para completar la responsabilidad por animales regulada en el Código Civil, se dictó la "Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía" (Ley 21020), más conocida como "Ley Cholito". Sobre dicho cuerpo normativo, se ha discutido sobre si introduce modificaciones al estatuto general consagrado en el Código, o si más bien viene a ser un mero complemento de dicho estatuto. Al respecto, parece pertinente leer algunas reflexiones de quienes han discutido de la materia.

De acuerdo al profesor Hernán Corral, pareciera que la directriz fundamental de la ley se encontraría en el inciso primero del artículo 13, que reza: *"Todo responsable de un animal regulado en esta ley responderá siempre civilmente de los daños que se causen por acción del animal, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda"*. Al referirse a "todo responsable", la norma se refiere al dueño o poseedor.

Pero, a continuación, hay que señalar que no solo el dueño o poseedor será responsable por los daños derivados de la acción del animal, sino que también asume la responsabilidad civil la persona que tenga a su cuidado el animal al momento de los daños. Pero, en este caso, la responsabilidad será de forma subsidiaria: "Será

responsable de las mascotas o animales de compañía su dueño o poseedor. Sin perjuicio de lo anterior, quien tenga un animal bajo su cuidado responderá como fiador de los daños producidos por éste, en los términos establecidos en el Título XXXVI del Libro Cuarto del Código Civil.”

Es decir, la responsabilidad del mero tenedor sólo se hace efectiva en la medida en que no se pueda obtener la reparación del daño del principalmente responsable (esto es, el dueño o poseedor). Se aplicará entonces a este cuidador no dueño el estatuto propio de la fianza y gozará, por tanto, de un beneficio de excusión para que se demande en primer lugar al dueño o poseedor.⁹⁵ Así, aquí encontramos una modificación al estatuto general pues, como bien sabemos, en materia extracontractual, en virtud del art. 2317, la regla general es que se responda solidariamente, y no en subsidio como se consagra en esta ley especial.

Una segunda discusión dice relación con la expresión “responderá siempre” que emplea el mismo artículo y si, a través de esta, se estaría modificando el estatuto de presunción de culpa consagrado en el art. 2326 por uno de responsabilidad objetiva que no admite descarga alguna, dejando obsoleto dicho artículo. El profesor Hernán Corral es partidario que no se estaría consagrando una responsabilidad estricta con dicha expresión, principalmente porque carecería de sentido distinguir los animales fieros de los domésticos y porque el artículo 2 de la misma ley al definir tenencia responsable, habla de *adoptar medidas para evitar que la mascota causen daños*, dando a entender que sería posible la admisión de descargas de responsabilidad, cuando no se pudieron tomar dichas medidas.

⁹⁵ Ley “Cholito” y responsabilidad civil por daños causados por animales, Hernán Corral.